

제1장 총설

제1장 총설

1. 채권집행절차란

민사집행법은 제2편 제2장 제4절 제3관에서 동산집행의 일부로서 「채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행」에 대하여 규정하고 있다.

그 중 「채권에 대한 집행」은 다시 금전채권에 대한 집행과 유가증권, 그 밖의 유체물의 인도청구권에 대한 집행으로 나누어지고(민집 제223조), 「그 밖의 재산권에 대한 집행」은 부동산, 유체동산, 채권 이외의 재산권에 대한 강제집행을 의미하는데, 후자에는 원칙적으로 채권에 대한 강제집행을 준용하도록 되어 있다(민집 제251조). 이와 같은 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행을 모두 합하여 통상 「채권집행 또는 권리집행」이라고 부르고 있다.

대여금이나 매매대금 등과 같은 금전의 지급을 목적으로 하는 채권을 가지고 있지만 채무자에 의한 임의의 이행이 없는 경우, 채권자는 국가권력인 집행기관에 의해 채무자의 재산을 강제적으로 환가하는 방법으로 채권의 회수를 도모하게 된다. 이러한 때에 채무자의 재산이라고 떠올릴 수 있는 것들은, 부동산·동산류·급료나 임료 등의 채권이지만, 그 중에서는 부동산이 가장 환가액이 크고 그에 따라 회수할 수 있는 금액도 많기 때문에 강제집행절차와 그 절차를 다룬 민사집행법 가운데에서는 부동산 집행절차가 중심적인 위치를 차지하고 있다.

그 때문에 부동산집행절차에 관해서는 비교적 그 이론이 정치하게 정립되어 있고 또한 그에 대한 생각도 더 친숙한 느낌을 받고 있지만, 채권집행절차의 경우는 실제 그것이 우리 생활에서 미치는 광범위한 영향에도 불구하고 부동산집행절차보다 그 이론 체계가 덜 세워져 있으며, 어느 면에서 본다면 부동산집행절차에 부수적인 것 또는 종된 것이라는 취급을 받아 온 것이 지금까지의 실무 상황이기도 하였다.¹⁾

2. 민사집행법의 제정·개정

우리 대법원은 1960년의 구 민사소송법 제정 이래 큰 변화가 없이 유지되어 온

1) 이러한 채권등 재산권에 대한 강제집행이 부동산등에 대한 강제집행과 다른 특성은, 우선 그 권리가 관념적인 성격을 가진 만큼 그 집행방법도 법원의 재판에 의해야 한다는 점이고, 또 다른 특성은 채무자 외에 그러한 권리의 의무자인 제3자도 이른바 제3채무자로서 집행절차에 관여하게 된다는 점 등을 들 수 있다.

4 제1장 총설

민사소송제도 및 민사집행제도의 개선을 바라는 국민의 의견을 적극적으로 수용하고, 그 동안의 제도 운영 경험과 사회문화의 변화 추세를 반영하는 새로운 민사소송제도 및 민사집행제도를 마련하기 위해 실무계와 학계의 역량을 총집결하여 1995년부터 구 민사소송법 전반에 대한 개정작업에 착수하였고, 이에 따라 2001. 12. 6. 국회 본회의에서 대법원안과 정부안 등 두 법안이 통과되었으며, 2002. 1. 26. 지금 우리가 다루고자 하는 채권집행절차가 포함된 민사집행법이 공포되었고, 그 후 2002. 7. 1.부터 위 법률이 시행되고 있다.

이와 같이 하여 새로이 제정된 민사집행법은 구 민사소송법 중 집행절차편을 전면적으로 개정하여 별도의 단행 법률로 만든 것으로서 집행의 실효성을 확보하기 위한 다수의 제도적 장치들을 도입하고 있는데, 새로운 민사집행법의 제정으로 구 민사소송법과 현저하게 달라진 부분을 들자 하면, 부동산집행의 경우에는 배당요구의 종기제도(민집 제84조)를 도입하여 매각조건을 조기에 확정시킨 부분일 것이고, 채권집행의 경우에는 채권집행 또는 배당의 기초가 되는 집행공탁, 특히 그 중에서도 제3채무자에 의한 공탁에 관하여 광범위하게 권리공탁을 인정한 부분이라고 볼 수 있을 것이다. 그리고 이러한 집행공탁제도의 두드러진 변화는 그 공탁 이후의 절차를 담당하는 채권집행 또는 채권배당절차에서 또한 많은 발전적 변화를 가져왔다고 보여지고, 또 경제가 오늘날과 같이 발전하기 이전에는 부동산이나 동산과 같은 유체물이 주로 강제집행의 대상이 되었으나 경제가 발전하면서 채권이나 그 밖의 재산권도 부동산 등에 못지 않은 중요한 재산적 가치를 갖게 되었으며 이에 따라 그에 대한 강제집행의 비중도 점차 높아지게 되었다. 그로 인해 지금의 실무상 위와 같이 달라진 채권집행절차에 관한 법이론의 정립이 시급히 요구되고 있는 실정이다.

3. 책의 구성 및 내용

가. 채권 등 재산권에 대한 압류, 현금화, 배당등과 같은 채권집행절차의 전반을 다루게 되는 이 책의 구성은 보다시피 합하여 11개의 장으로 이루어져 있다.

그 중 제1장부터 제6장까지가 상권을 이루고 있으며, 나머지 제7장 「당사자승계」부터 제11장까지가 하권을 형성하도록 하였다. 이러한 구분은 개개의 채권자가 압류, 추심 또는 전부를 하면서 또한 다른 채권자들과 경합되어가는 채권집행절차를 상권에 배치하고, 그 이후의 절차를 하권에 위치하도록 한 것이라고 볼 수 있다.

나. 여기에서 이 책이 구분하고 있는 위 각 장들의 내용을 간략히 개관해보면

다음과 같다.

1) 그 중 맨 처음에 머리를 내밀고 있는 제1장은 바로 이 책의 구성을 개략적으로 설명하고 있는 여기서의 총설이 바로 이에 해당한다. 그 다음에 등장하는 제2장은 채권집행에 있어서 집행법원이 가지는 의미를 고찰해보고 있다.

2) 나아가 제3장으로 발을 돌리면, 채권집행절차의 개시를 알리는 압류명령부분이 나오게 된다. 즉 금전채권에 대한 집행은 압류, 현금화, 변제의 3단계로 실시되며, 채권자가 집행법원에 집행신청(압류명령의 신청)을 하면 집행법원은 압류명령을 발령하여 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류한 후(민집 제227조 제1항), 다시 채권자의 신청에 의하여 추심명령 또는 전부명령 등을 발령하여 현금화하게 되는 것인바(민집 제229조 제1항), 이러한 모든 향후 절차의 전제가 되는 것이 채권에 대한 압류명령인 것이다. 압류명령에 관한 제3장은 살펴볼 것이 많아서 이 책에서 차지하는 비중도 적지 아니하다. 그리하여, 서론부분인 제1절을 넘어서게 되면 제2절에서는 압류명령의 일반론으로서 그 내용, 효력 등을 일견하게 되고, 제3절에서는 공익적, 사회정책적인 이유 등으로 압류를 할 수 없는 채권, 다시 말해 압류금지채권에 대한 논의를 언급하고 있다. 제5절 이하에서는 일반채권의 범위를 살짝 넘어서서 지시채권의 압류(제5절), 그 밖의 재산권에 대한 압류(제6절), 채권 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행(제7절), 유체물의 인도청구권에 대한 강제집행(제8절) 등의 문제를 다루고 있다.

3) 그리고 제4장과 제5장은 위의 압류명령을 전제로 하는 현금화단계를 다루고 있다.

채권집행에 있어서 금전채권의 압류만으로써는 압류채권자의 집행채권에 만족을 줄 수 없으므로, 압류채권자는 자기채권의 만족을 얻기 위해서는 압류한 금전채권을 현금화할 필요가 있게 되고, 이를 위하여 민사집행법 제229조는 금전채권의 현금화방법으로서 추심명령과 전부명령을 규정하고 있으며, 금전채권의 현금화방법으로는 그밖에도 민사집행법 제241조에 정해진 특별현금화방법으로서의 양도명령, 매각명령, 관리명령 및 그 밖의 상당한 방법에 의한 현금화방법 등이 있으나, 이들은 특별한 경우에만 인정되는 예외적인 현금화방법에 해당하고, 원칙적인 현금화방법은 위 제4장과 제5장에서 취급하고 있는 추심명령과 전부명령이라 할 수 있다.

또한 개정판에서는 실무에서 그에 관한 소송이 많이 제기되고 있는 실정이나, 연구 성과가 그리 많지 않았던 추심소송에 대하여 상당한 지면을 할애하여 설명을 하

고 있다.

4) 제6장은 「집행의 경합」에 대하여 취급하고 있는데, 이 장에서는 채권집행에서 채권자가 여러 명이 있는 경우, 즉 채권자가 경합하는 경우에 관한 대표적인 예로서 압류의 경합과 배당요구를 설명하고 있다. 우리 민사집행법이 규정하는 압류의 경합이란 개념은 중복된 집행에 대하여 채권자평등주의의 실현을 위한 압류효 확장, 공탁의무, 배당요구의 효력 등 일정한 법적 효과를 부여할 것인지 아닌지에 관한 문제이다.

그리고 여기까지가 앞서 보았듯이 이 책의 上卷에 포함되어 있는 영역들이다.

5) 잠시 틈을 들인 후에 이 책의 하권으로 걸음을 옮겨보면, 제7장의 「당사자승계」를 만날 수 있다. 여기에서는 강제집행에 있어서 집행권원이 성립된 후 집행개시까지 사이에 당사자의 변동이 있었던 경우 또는 담보권실행에 있어서 당사자에게 승계가 있었던 경우에 생길 수 있는 문제들을 언급하고 있다.

6) 제8장에서는 집행공탁의 문제를 취급하고 있다. 즉 채권집행절차는 채권자의 신청에 따라 발부된 집행법원의 압류명령에 의해 개시되는데, 이 단계의 경우 그 절차 진행의 주도권은 집행법원이 아니라 당해 압류명령을 신청한 압류채권자에게 있다고 보아야 할 것이다. 물론, 여기서도 집행법원은 압류명령 발령 여부를 심사하는 등으로 절차진행에 관여하기는 하지만, 이는 어떻게 보면 당사자의 권리행사에 대해 보조적으로 이를 지원해주는 역할에 머무르고 있다고 볼 수 있다. 그리하여 압류채권자는 다른 채권자들이 경합하지 않는 한 위 압류명령에 기초하여 다시 추심명령 혹은 전부명령 등을 얻어 제3채무자에 대해 추심 또는 지급청구함으로써 자기 채권의 만족을 받을 수가 있게 되는 것이며, 그로써 집행절차는 종료하게 되는 것이다.

그러나 예컨대 압류채권자가 전부명령을 얻은 경우라도 그 이전에 다른 압류 또는 가압류가 있어서 전부명령이 효력이 생기지 않아 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항에 따라 공탁한 경우 혹은 위 압류채권자가 추심명령을 얻어 제3채무자에 대해 추심권을 행사하였지만 제3채무자가 이에 응하지 않고 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁해버린 경우 또는 채권자가 추심을 하였으나 추심신고 전에 다른 집행이 경합되었기 때문에 추심한 금액을 공탁한 경우 등과 같이 채권집행에서 집행공탁이 이루어진 다음에 있어서는 위 절차 진행의 주도권이 이제는 집행법원에게로 옮겨가게 된다.

그리하여, 위와 같이 공탁된 돈에 대한 관리권이 이제는 집행법원에게로 넘어가

고, 또한 그 이후 권리자를 확정하는 절차의 진행권 역시 집행법원에게 있게 되며, 나아가 권리자로 확정된 자에게 돈을 지급해달라는 취지의 공탁소에 대한 지급위탁의 권한 등 역시 집행법원만이 가지게 된다. 따라서 채권집행에 있어서 집행공탁부분은 돈이 집행법원에게로 흘러들어오는 관문의 역할을 하고 있고, 또한 그 돈이 다시 권리가 확정된 채권자에게로 흘러나가는 관문에 해당된다고 볼 수 있다.

그래서 집행공탁을 자세히 살펴보게 되면 과연 집행에 필요한 돈이 어떻게 집행법원으로 흘러들어오고 또 집행법원에서 그것이 어떻게 처리되며, 나아가 결국 어떤 경로를 통해 다시 집행법원으로부터 그것을 필요로 하는 사람에게 흘러나가게 되는지를 알 수 있게 되는데, 그러한 「돈의 흐름」 그 자체가 바로 채권집행절차 또는 채권배당절차라고 말할 수 있는 것이다. 또한 위와 같이 집행법원으로 돈이 흘러들어오는 관문의 자리에 위치하고 있는 집행공탁단계에서 발생하는 그로 인한 법률관계 혹은 효과는 그 자체가 상당히 복잡한 이론적 문제점을 안고 있는 것인바[예를 들어, 그 공탁이 집행법원에 미치는 영향(배당등 절차의 개시 가능, 배당가입의 차단효 발생), 압류채권자에게 미치는 효과(압류명령의 존재의 상실, 소급적 복멸을 가져오는 취하, 취소 등 불가), 제3채무자에게 미치는 영향(채무의 변제효), 다른 채권자들에게 미치는 영향(배당가입이 차단되어 그 이후에는 배당등 절차에 가입이 불가) 등], 이와 같은 효과 내지 영향이 어떻게 결정되는가에 따라 그 이후에 진행되는 전체 채권집행절차의 운명이 좌우되고 만다.

또한 집행공탁과 관련해서는 현행법상 공탁제도 등의 문제점에 대하여 많은 관심을 기울여 주기를 바라는 마음이다.

대법원이 앞서 본 바와 같이 민사집행법을 대폭 개정하였으나, 다만 실무에서 논란을 일으키고 있는 부분을 그대로 뒤흔드는 바람에 여전히 문제를 낳고 있는 실정이다. 이것이 무슨 말인가에 대해 조금만 터치하고 간다면, 현행법상 제3채무자의 의무공탁을 규정한 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 구법과 동일하게 그야말로 불완전한 의무공탁규정(채권자가 경합하는 경우 당해 채권자의 공탁청구가 있을 때에만 제3채무자에게 공탁할 의무를 부여함)으로 남아 있게 됨으로써, 채권자가 경합하는 상황이라도 누구든지 먼저 제3채무자로부터 채권을 지급받은 자가 우선하게 되는 결과에 이르게 되었고(제3채무자로부터 먼저 추심한 채권자는 이를 민사집행법 제236조에 따라 추심신고를 하여야 하지만, 이를 강제하는 규정이 없어서 별무소득이라고 볼 수 있음), 이는 우리 민사집행법이 그 기초를 두고 있는 채권자평등주의에

8 제1장 총설

반하는 것이어서 결국은 다른 채권자의 권리를 해치고 있는 현실이 되고 만 것이다. 따라서 이 부분에 대하여는 차후 연구를 거듭하여 그 개정작업이 이루어져야 한다고 본다.

7) 위 제8장을 거친 후 제9장에서는, 실무상 인정되고 있는 혼합공탁에 관한 이론을 다루고 있다. 혼합공탁이란, 공탁원인사실 및 공탁근거법령이 다른 실질상 두 개 이상의 공탁을 공탁자의 이익보호를 위하여 하나의 공탁절차에 의해 하는 공탁을 말하는데, 실무에서 가장 흔하게 접하게 되는 채권양도와 관련된 혼합공탁의 경우를 예로 들자면 이는 채권양도 등과 압류명령 중 어느 쪽이 유효로 인정되는 것을 정지 조건으로 하여 면책을 인정하는 공탁을 의미하는 것이다. 실무가 이러한 혼합공탁을 인정하고 있는 이유는 집행공탁의 그것과 약간은 중복되지만, 간단히 말하면 법률 또는 공탁법리에 정통하지 못한, 그리고 자신의 의도와 관계없이 채권자와 채무자 사이의 채권관계 등 법률관계에 휘말려 들어간 제3채무자, 즉 공탁자의 이익을 보호하는데에 있다고 보면 될 것이다.

8) 위 제9장을 지난 다음에 제10장에서 나타나는 것은, 바로 어쩌면 채권집행절차의 최종적인 목적이라고 할 수 있는, 배당등 절차이다. 위 배당등 절차는 바로 집행법원에 의해 강제적으로 행해지는 채무자의 채권자에 대한 채무변제절차이다. 이것에 의해 채권자는 드디어 이제까지 행해왔던 모든 민사절차, 즉 보전처분을 행하고 또 모든 증거방법을 동원하여 집행권원을 얻었던 등으로 이어져 왔던 노력의 대가를 받게 되는 것이다.

부동산집행이든 혹은 채권집행이든 모두 채무자의 재산을 압류하고 집행기관이 재산을 매각하거나 압류를 한 채권자가 직접청구를 하거나 함으로써 변제에 충당할 수 있는 금전으로 현금화한 다음 압류 등을 한 채권자에게 지급되는 「압류 → 현금화 → 만족」의 과정을 밟아나가게 되어 있는 것은 같으나, 다만 부동산집행의 경우에는 만족을 얻으려면 그 종국에 거의 필연적으로 배당등의 절차가 예정되어 있지만, 우리가 지금 살펴보고 있는 채권집행에 있어서는 다른 경합하는 채권자가 없을 경우 청구된 금전은 집행법원에 의한 절차를 거침이 없이 지급을 청구한 채권자의 채권에 충당되어질 수가 있기 때문에 반드시 위와 같은 배당등의 절차를 거쳐야만 그 절차가 종료된다고 말할 수는 없는 것인바, 바로 이와 같은 것이 부동산배당절차와 채권배당절차의 가장 기본적인 차이점이라고 할 수 있다. 이러한 기본적인 차이점 외에 채권배당이 부동산배당과 어떻게 구체적으로 다른 모습을 보이는가에 대하여는 위 제10장

의 제2절이 다시 그 설명을 덧붙여 두고 있다.

9) 어찌되었든 제10장이 마련하고 있는 배당등 절차를 지나오게 되면 당해 집행의 목적물에 관해서는 채권자가 이른바, 만족을 받게 된 상태에 이르게 되므로 채권 집행절차 또한 더 이상 나아갈 필요가 없다. 하지만 절차의 진행이 이리함에도, 이 책이 제11장을 하나 더 두어 회생·파산절차가 진행된 채무자에 대해 채권압류명령 등이 발령되었을 때의 문제점 등을 살펴보고 있는 것은 마지막에 이른 글의 균형을 잡기 위함이다.

회생절차란 재정적 어려움으로 인하여 파탄에 직면하였으나 경제적으로 갱생의 가치가 있는 채무자에 대하여 채권자, 주주 기타 이해관계인의 법률관계를 조정하여 그 사업의 정리 재건 및 효율적인 회생을 도모하는 제도를 말하고, 파산절차란 채무자에게 파산의 원인이 있을 때 파산선고를 하고 채권조사절차를 통하여 채권자의 권리를 확정하고 다음 채무자의 재산을 환가하여 권리의 우선순위와 채권액에 따라 환가된 금원을 분배하는 과정을 말하는데, 채무자에 대한 이러한 회생절차 또는 파산선고가 그 채무자에 대해 채권압류명령이 발령된 후에 된 경우가 있고, 또한 실제로는 채권압류명령 발령 전에 회생절차 또는 파산선고가 있었으나 그 사실이 채권압류명령 후에야 판명된 경우도 있는바, 이러한 경우 집행절차를 어떻게 취급할 것인가에 관하여 언급하면서 위 제11장이 이 책의 대미(大尾)를 장식하고 있는 것이다.

다. 이와 같이 하여, 이제 본서는 모두 11장에 걸쳐 채권집행절차가 가지는 특징과 그 절차의 진행 등에 관한 모든 것을 살펴보는 긴 여정을 시작할 것이다.

제2장 집행법원

제2장 집행법원

I. 서설

채권집행은, 지방법원이 사물관할을 가지고, 토지관할에 대하여는 원칙적으로 채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 관할법원이 되지만(민집 제224조 제1항), 채무자가 보통재판적 소재지를 가지지 않는 때에는 제3채무자의 보통재판적 소재지(물건의 인도를 목적으로 하는 채권 혹은 물상담보권에 의해 담보된 채권에 대하여는 그 물건의 소재지)를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 제224조 제2항). 이는 전속관할¹⁾이므로(민집 제21조), 당사자가 합의에 의해 변경할 수 없다.

그런데 이와 같이 하여 토지관할을 가지는 집행법원이 압류명령을 발한 후에 채무자 또는 제3채무자의 보통재판적(일반적으로는 주소에 의해 정해지는 것으로 되어 있다. 민소법 제3조)이 변경되어도 관할 법원은 변경하지 않으므로[관할법원의 항정(恒定)], 그 피압류채권의 현금화절차로서 발하여진 추심명령, 전부명령 등은 압류명령을 발한 법원이 관할권을 가지게 되며, 배당등의 절차도 그 법원이 관할권을 가진다.

그러나 동일채권에 대하여 중복하여 채권집행이 있었던 때에는 신청시에 관할의 유무가 정해지는 것으로 되므로 채무자 또는 제3채무자의 보통재판적 변경에 의해, 동일채권에 대하여 집행법원을 달리하는 집행이 행해지는 경우도 발생할 수 있다.

그리고 이러한 경우에는 현금화절차(예컨대, 양도명령, 매각명령 등)이나 배당등의 절차를 동일법원에서 행하는 것이 바람직할 수 있기 때문에, 사건의 이송을 인정할 것인지에 관한 문제가 발생한다.

집행법원에 관한 민사집행법 제224조는 금전의 지급 또는 물건의 인도를 목적으로 하는 채권에 대하여 적용되고, 또 본조의 규정은 그 밖의 재산권에 대한 강제집행에도 준용되어 있다(민집 제251조).²⁾ 또 위 제224조에 의한 관할의 유무는 각 채무

1) 전속관할이란 관할을 법으로 정함에 있어 재판의 적정·공정 등 고도의 공익적 요구에 의하여 특정 법원만이 배타적으로 관할을 가지게 하는 경우를 말한다. 심급관할 등의 직분관할은 원칙적으로 전속관할이지만, 심급관할에서 비약적 상고가 인정되는 범위에서는 임의관할이 된다(민소 제422조, 제390조 제2항 단서, 제433조).

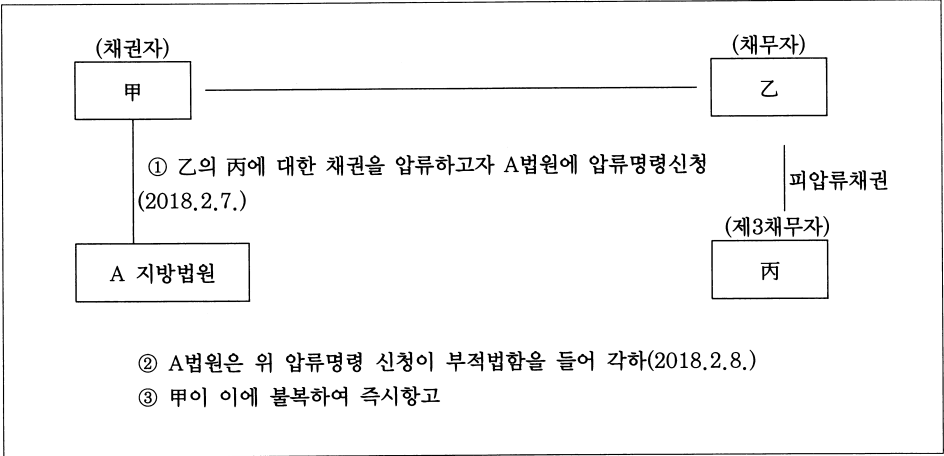
2) 다만 그 밖의 재산권 중에서 권리이전 등에 있어서 등록 등을 요하는 특허권, 저작권 등은, 그 등록 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원 소재지에 관할이 있다(민집규 제175조 제2항, 민집 제251조 제1항, 제224조 제2항).

자마다 개별적으로 판단된다.³⁾

II. 채권집행의 사물관할

채권집행에 대하여는, 지방법원 단독판사가 집행법원이 된다(민집 제224조 제1항). 이와 같이 지방법원이 집행법원으로 되어 있는 것은, 집행절차에는 신속성이 요구되고, 이해관계인의 이해 조정(특히, 배당등의 절차에 있어서)에 복잡한 사안도 예상되며, 또 재량부분(특히, 현금화절차)도 크기 때문이다.

1. 즉시항고에 의한 취소의 경우



위의 사례에서 만일 항고법원이 A지방법원의 각하결정이 부당하다고 보아 취소하고자 한다면, 항고법원은 위 재판을 취소하는 데에서 나아가 새로운 압류명령을 발할 수 있다고 볼 것인가.

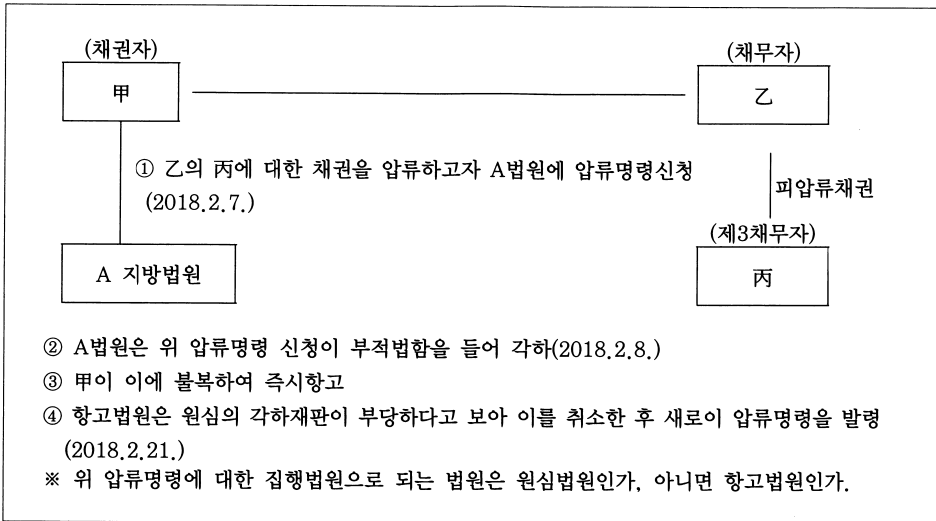
만약 지방법원이 아니라면 집행법원이 아니고, 또 집행법원이 아니라면 압류명령을 발할 수 없다고 해석하면, 이 경우 항고법원은 스스로 압류명령을 발할 수 없으므로 단순히 파기환송해야만 한다는 결론이 될 것이다.

그러나 항고법원의 절차에 대하여는 그 성질에 반하지 않는 한 항소에 관한 규정이 준용되고 있고(민집 제23조, 민소법 제443조 참조), 항소심 구조에서는 항소심의 심리결과 제1심의 재판이 부당하면 그것을 취소, 나아가 심리를 계속해야 한다고

3) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 315.; 岩野徹 外 編, 注解強制執行法(2), 第一法規出版株式會社(1974), 267.

판단된 때에는 사건을 제1심법원에 환송해야 하지만, 재판하기에 성숙하다고 판단한 때에는(채권집행의 신청을 각하한 재판을 부당하다고 판단한 때가 이에 해당할 것이다), 스스로 재판을 하는 것(압류명령을 발하는 등이 이에 해당한다)이 가능하므로 항고법원도 즉시항고에 의해 압류명령을 발하는 것이 가능하다고 본다.^{4) 5)}

2. 항고법원이 압류명령을 발한 경우의 집행법원



이에 대하여 이 경우에는 예외적으로 항고법원이 집행법원으로 된다는 견해도 있을 수 있지만, 사후의 현금화절차, 배당등의 절차 또는 배당이의의 소(이는 배당을 실시한 집행법원이 속한 지방법원이 관할한다. 민집 제156조 제1항) 혹은 제3채무자의 소(이는 집행법원이 관할한다. 민집 제48조 제2항) 등과의 관계를 고려하면, 이 경우에도 여전히 지방법원이 집행법원으로 된다고 보아야 할 것이다.⁶⁾

3. 가압류집행에 있어서의 집행법원

채권의 가압류집행에 있어서는 가압류명령을 발한 법원이 집행법원으로 되기 때문에(민집 제278조), 지방법원 외에 가정법원 또는 고등법원이 집행법원이 될 수도

4) 吉野 衛・三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(6), きんざい, 平成 7年(1995), 79.

5) 이와 같이 항고법원이 압류명령을 발한 경우에는, 속심구조하에 있는 항고법원이 지방법원의 권한을 대위행사하고, 그 결과 제1심법원으로서의 지방법원이 재판한 것과 동등한 효과가 생기는 것이라고 해석하면 될 것이다.

6) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 79.

있다. 가압류집행에 있어서는 처분제한을 과할 뿐이고, 그 후의 배당등 절차가 예정되어 있지 않아서 집행법원을 지방법원에 한정할 필요가 없기 때문이다.

그리고 채권의 가압류에서 이전되는 채권압류의 경우에는 가압류를 명한 법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 제224조 제3항).

Ⅲ. 채권집행의 토지관할

1. 채무자의 보통재판적 소재지(민집 제224조 제1항)

가. 채무자가 개인인 경우의 보통재판적

1) 원칙적 관할

가) 채권집행은, 원칙적으로 채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되어 있고(민집 제224조 제1항), 개인의 보통재판적은 원칙적으로 주소에 의해 정해지게 되므로(민소 제3조 참조), 채권집행은 제1순위로 채무자의 주소지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다.

나) 이 「주소」의 정의에 관하여는 별도의 정의 규정이 없으므로 민법의 정의에 따라야 한다. 민법상 주소란 생활의 본거지를 의미하고 있으므로 채무자에게 주소가 있다고 말할 수 있는가 아닌가는 그것이 본인의 생활의 본거지인가 아닌가에 달려있다. 그것이 객관적으로 생활의 본거지로 간주되는 한, 본인이 그것을 상주(常住)의 장소라고 정하여 생활의 본거지로 할 의사가 없는 경우에도 주소로 보아도 되고, 또 그와 같은 생활의 본거지로 간주되는 것이라면, 복수의 주소를 가지는 것도 인정할 수 있다.

다) 이같이 주소가 복수 존재할 수 있다고 하면, 집행법원으로 될 수 있는 법원도 복수 존재할 수 있게 되고, 이 경우에 어느 법원에 채권집행의 신청을 하는가는 채권자의 선택에 맡겨져 있다. 이 경우에는 신청을 받은 법원이 집행법원으로 되지만, 그 외에도 관할법원이 있기 때문에, 이론적으로만 본다면, 이송의 재판을 할 수도 있을 것이다(다만 이송이 상당하지 않는 경우가 많을 것이다).

라) 이와 같이, 채권집행에 있어서 채무자의 보통재판적의 소재지를 관할하는 지방법원이 제1순위로 관할법원으로 되어 있는 것은, 채권등을 목적으로 하는 집행절차에 있어서는 압류명령 발령시에 채무자 및 제3채무자를 심문하지 않는 점(민집 제226조), 이에 대하여 불복이 있는 채무자등은 압류명령의 고지를 받은 날로부터 1주

일의 불변기간 내에 즉시항고를 해야 하는 점(민집 제227조 제4항, 민집 제15조), 위 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없는 점(민집 제15조 제6항) 등에 비추어 집행채무자에게 방어의 기회가 제한된 것으로 볼 수 있으므로 이러한 채무자에게 실질적으로 방어의 기회를 보장될 수 있도록 하고 또 채무자의 보통재판적이 있는 곳에 이해관계인이 많이 존재한다는 것 등에서 착안 한 것이고, 나아가 그것이 배당요구를 하게 되는 채권자의 이익에도 도움이 된다는 점을 모두 고려한 것이다.

마) 이에 대하여 부동산집행에 있어서는 당해 부동산소재지를 관할하는 지방법원, 즉 집행목적재산에 근접한 곳을 집행법원으로 하고 있는 점과 관련하여, 입법론적으로 채권집행에서도 집행목적재산의 소재지라고 볼 수 있는 제3채무자의 보통재판적 소재지를 제1순위의 집행법원으로 함이 적절하다는 견해도 있을 수 있지만, 채권은 특정물의 인도를 목적으로 하는 것을 제외하고 특약이 없는 한 채권자의 주소가 변제의 장소인 점, 채무자의 주소지 법원이 집행기관으로 되는 것이 당해 채무자와 관계된 채권자에게 오히려 편리할 수 있는 점 등을 감안하면 채무자의 보통재판적 소재지를 제1순위의 기준으로 정하는 것이 보다 합리적이라도 생각한다.

2) 국내에 주소가 없는 경우

가) 채무자 중에는 국내에 생활의 본거지라고 할 수 있는 것이 없거나 혹은 그러한 곳을 알 수 없는 경우에는 거소지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되지만(민소 제3조 참조), 위 거소란 주소와 달리 다소 계속하여 거주하는 장소를 의미한다고 해석된다. 예컨대, 장기입원하고 있는 병원, 재학생의 하숙집, 기숙사 등이 이에 해당한다.

나) 거소란 생활의 본거지라고 말할 정도의 것은 아니므로 주소가 있다고 하기 위해서는 영주체제의 의사가 필요하지 않은 것은 물론이고, 또한 주소가 복수 존재할 수도 있다. 이와 같이 주소가 복수 존재하여 그로 인해 복수의 관할법원이 있는 때에, 어느 법원이 집행법원이 되는가에 관하여는 앞서와 마찬가지로 채권자의 선택에 의할 것이다.

다) 그리고 국내에 주소 또는 주소가 없는 경우, 있어도 그 곳을 알 수 없는 경우 등에는 채무자의 최후주소 소재지의 지방법원이 집행법원으로 된다(민소 제3조 참조). 최후주소에 한정되므로 주소가 이전되거나 변경된 때는 그 최후의 것을 의미한다.

3) 채무자 소재의 증명

가) 그런데 채무자에게 주소, 그것이 없는 때에는 주소, 다시 그것이 없는 때에

는 최후의 주소 등이, 신청을 받은 법원의 관할지역에 소재하는 것이 당해 신청을 받은 법원에 대해 관할을 인정하는 이유이므로 채권집행의 신청을 함에 있어서는 신청을 하는 지방법원의 관할 내에 채무자가 소재함을 증명할 필요가 있다.

나) 또한 채무자의 거소 또는 최후주소의 소재지를 관할하는 지방법원에 대하여 채권집행의 신청을 한 때에는, 채권자는 채무자에게 주소가 없는 점, 또는 불명인 점을 입증한 다음에 동인의 거소가 신청을 한 법원의 관할 내에 존재함을 증명해야 하고, 최후의 주소지에 신청을 하는 경우에는, 채무자에게 주소도 거소도 국내에 없거나 그 어느 것도 불명인 점을 입증하는 것에서 나아가 최후의 주소가 관할 내에 소재하는 것을 증명할 필요가 있다.

다) 이러한 증명에 대하여, 최후의 주소가 있었던 것의 증명은 가족관계증명서, 주민등록등(초)본 등에 의해 가능하지만, 채권자 그 밖의 자의 진술서 혹은 심문에 의해야 하는 경우도 있을 것이다.

4) 복수의 채무자가 있는 경우 등

가) 복수의 채무자에 대한 신청이 있었던 경우에는 각 채무자마다의 보통재판적에 의하여 집행법원이 정해지게 된다(민소 제65조)는 민사집행에 있어서는 적용이 없다. 또 민소 제31조, 제25조 참조).

나) 또한 집행권원이 피상속인에 대한 것이어도 상속이 개시되면 각 상속인은 그 지분에 따라 분할된 채무를 부담하게 되므로 각 상속인에 대한 채권집행의 토지관할은 각 상속인 별로 정해지게 된다.⁷⁾ 유언집행자가 선임되어 있는 경우(민법 제1103조)도 유언집행자는 상속인의 대리인으로 간주될 뿐이므로 위와 동일하다.⁸⁾

다) 이에 대해, 상속인이 누구인가 명확하지 않은 경우에는 상속재산관리인이 선임되므로(민법 제1053조), 그 관리인의 주소 등이 채무자의 주소 등에 해당한다(민소 제5조 제1항 후단).⁹⁾

라) 파산재단에 속하는 채권을 압류한 경우도 위와 동일하게 파산관재인인의 보통재판적에 의해 관할을 정하게 된다.¹⁰⁾

마) 채권질권의 설정자(담보제공자)와 그 질권에 의해서 담보되는 채권의 채무자

7) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 315.

8) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 82.; 日最判 昭和 30(1955). 5. 10.(民集 9-6, 657) “유언집행자가 상속인의 대리인으로 간주된다고 해서 반드시 상속인의 이익을 위해서만 행위해야 할 책무를 지는 것은 아니다.”

9) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例タイムズ社, 7.

10) 鈴木忠一 = 三月章 責任編集, 注釋民事執行法(4), 第一法規出版株式會社(昭和 60), 399.

가 다른 경우에 강제집행의 방법에 의한 질권의 실행에서는 집행채무자가 되는 것은 압류의 목적인 채권의 채권자(담보제공자)이고, 피담보채권의 채무자는 아니다. 따라서 예컨대 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 자신의 채권자인 甲에게 질권을 설정하여 담보로 제공한 경우 甲이 강제집행의 방법에 의하여 위 질권을 실행할 경우 그 채무자는 乙이므로 乙의 보통재판적에 따라 관할을 정하여야 한다.

나. 채무자가 법인 기타 사단·재단인 경우의 보통재판적

1) 원칙적 관할

채무자가 법인 등인 경우에 그 보통재판적은, 제1순위로서는 주된 사무소(비영리 법인이 그 업무를 행하는 장소) 또는 영업소(영리법인이 그 업무를 행하는 장소)에 의해 정해지지만(민소 제5조 참조), 사무소 또는 영업소는 등기사항으로 되어 있으므로 외관상 명확하고, 따라서 일반적으로는 그 등기된 주된 사무소 또는 본점의 소재지에 채무자 회사의 보통재판적이 있는 것으로 보면 될 것이다.

그러나 주된 사무소인가 아닌가는 사실상의 문제이므로 등기상의 주된 사무소나 본점보다도 업무의 중심을 수행하는 사무소 또는 영업소가 별개로 존재하면 등기상의 것 외에 그것도 주된 사무소 또는 영업소로 취급해야 한다.¹¹⁾

이 때문에 주된 사무소 또는 영업소가 복수 존재할 수 있지만, 이와 같이 집행법원이 복수 존재하는 경우에 어느 법원에 신청할 것인가는 채권자의 선택에 맡겨지게 될 것이다.

2) 특정한 사무소·영업소에 관련된 채무의 경우

채무자가 법인 기타 사단 또는 재단이고, 특정한 사무소·영업소에 있어서의 업무에 관한 채무에 대하여는 당해 사무소·영업소 소재지의 법원에도 訴에 대하여는 관할이 있는 것으로 되어 있는바(민소 제12조), 강제집행의 경우에도 피압류채권의 내용이 그와 같은 것이라면, 주된 사무소등이 아닌 사무소·영업소(예컨대, 지점 등)의 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원이 될 수 있다고 본다.¹²⁾

3) 주된 사무소·영업소가 없는 경우

법인 등에 대하여, 등기상의 본점 등에서 업무가 행해지지 않고 또 그 외에도 업무의 중심으로 되는 주된 사무소·영업소가 없는 때에는 법인의 대표자(이사, 대표이사 등) 또는 법인 아닌 사단 등의 경우에는 대표자 또는 관리인, 청산단계의 회사

11) 齋藤秀夫 編著, 注解民事訴訟法(1), 第一法規(1991), 88.

12) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 83.

에 있어서는 청산인 등 주된 업무담당자의 주소에 의해 법인 등의 보통재판적이 정해진다(민집 제5조 제1항 참조).

대표자등이 수인 있는 때는 그 중에서 주로 대표행위를 행하고 있는 자의 주소에 의해야 할 것이지만, 주종(主從)의 차가 없는 경우에는 어느 업무담당자의 주소소재지 법원도 관할을 갖게 되므로 어느 법원에 신청하는가는 채권자의 선택에 의한다.

이 경우에, 주된 업무담당자에게 주소가 없거나 그 주소를 알 수 없는 경우에는, 민소법 제3조를 준용하여, 그의 거소에 의해, 또 그것이 없는 때에는 최후의 주소에 의해 법인의 보통재판적을 인정할 수 있다는 것이 민소법상의 일반적 견해로 보이지만, 채권집행의 경우에는 채무자의 보통재판적이 존재하지 않는 때에는 제3채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되어 있으므로(민집 제224조 제2항), 주된 업무담당자등의 거소 등 소재지법원에 관할을 인정해야할 필요성은 적을 것이다.

다. 국가의 보통재판적 등

국가가 채무자로 되는 경우에 보통재판적은 소송에 대해 국가를 대표하는 관청의 소재지 또는 대법원 소재지에 있다.

또한 외국법인으로 상사회사 그 밖의 설립이 인가되어 있는 것 또는 인가되어 있지 않고 법인도 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자의 정함이 있는 것의 보통재판적은 내국법인 그 밖의 사단 또는 재단에 준하여 취급된다.

2. 피압류채권의 소재지(민집 제224조 제2항)

가. 물건의 인도를 목적으로 하는 채권의 소재지

물건의 인도청구권을 압류하는 경우에도 채무자의 보통재판적소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되는 것이 원칙이다.

그러나 채무자에게 보통재판적이 없는 때에는 물건인도청구권의 압류라는 특징으로부터, 그 물건의 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 제224조 제2항). 당해 물건에 대한 인도청구권 압류는 당해 선박, 유체동산, 자동차 등 집행의 선행절차에 불과하기 때문에 이와 같이 정한 것이다.

나. 물상담보권에 의해 담보된 채권의 소재지

채무자의 보통재판적이 없는 경우에, 피압류채권이 유체물(동산 또는 부동산)을 목적으로 하는 담보권(유치권, 질권, 저당권, 해석상으로는 양도담보권, 가등기담보권도 포함시킬 수 있다)에 의해 담보되어 있는 것인 때에 그 채권에 대하여는 담보물의 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 제224조 제2항).

채권압류명령을 얻은 채권자는 그 압류명령에 기해 추심명령을 발령받아 당해 채권을 담보하는 담보권을 실행할 수 있는 권한이 주어진다.

이때 실행이 가능한 담보권은, 물상의 것에 한하지 않고 채권질 등도 포함되지만, 후자의 경우 그 담보권의 실행은 복잡하고 획일적인 것이 아니므로 이러한 담보권에 의해서 담보된 채권에 대하여는 제3채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되는 것으로 하고, 이에 대해 물상의 담보권에 의해 담보되어 있는 채권에 대하여만 당해 물건의 소재지를 관할하는 지방법원을 집행법원이 되도록 한 것이다. 동산 또는 부동산에 대한 담보권의 실행은 그 목적물의 소재지에서 행해지는 것이 원칙이기 때문이다.

다. 제3채무자의 보통재판적 소재지

채권집행에 대하여 채무자가 보통재판적을 가지는 때는 그 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되지만, 그 보통재판적이 존재하지 않는 때는 위 가. 및 나.항의 경우를 제외하고 제3채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원이 된다(민집 제224조 제2항).

채권집행에 있어서는 제3채무자에 의한 채무이행(지급 또는 공탁)이 원칙적인 현금화절차이고, 따라서 제3채무자가 절차 중에 중요한 역할을 담당하고 있다고 할 수 있기 때문에, 채무자에게 보통재판적이 없는 경우에 제3채무자의 보통재판적에 의해 채권집행의 관할법원을 정하도록 하고 있는 것은 합리적이라 볼 수 있다.

이와 같이 제3채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되는 것은, 채무자의 보통재판적이 없는 점 및 제3채무자의 보통재판적이 신청을 하고 있는 지방법원의 관할구역 내에 있다는 점 등이 입증된 경우에 한정하는 것이므로 신청채권자는 이러한 것을 증명해야 하고 그 입증방법이나 보통재판적의 의미 등은 앞서 서술한 것과 같다.

3. 그 밖의 재산권에 대한 집행절차에 있어서 관할법원

집행법원에 관하여 규정하고 있는 민사집행법 제224조는, 민사집행법 제251조 제1항에 의하여 그 밖의 재산권, 예컨대 전화가입권, 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 무체재산권, 임차권, 가등기상의 권리, 골프회원권, 사원지분권(유한회사, 합명회사, 합자회사 등), 예탁유가증권 등에 대한 집행에 준용되도록 되어 있다.

따라서 채권집행절차와 동일하게 제1차적 관할은 채무자의 보통재판적의 소재지를 관할하는 지방법원이고, 이 보통재판적이 없는 때의 제2차적 관할법원은 압류해야 하는 재산권의 소재지를 관할하는 지방법원이다.

다만 그 밖의 재산권 중에서 권리이전 등에 관하여 등기·등록을 요하는 특허권, 저작권 등은 그 등기 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원 소재지에 관할이 있다(민집규 제175조 제2항, 민집 제251조 제1항, 제224조 제2항).

그러나 민사집행법 제251조 제1항이 그 밖의 재산권에 대한 강제집행은 금전 지급을 목적으로 하는 채권에 대한 집행절차를 준용하도록 규정하고 있는 점, 그 밖의 재산권에 대한 집행 또한 집행채무자의 권리방어상 편의를 도모함과 동시에 채무자의 보통재판적 소재지 근처에 이해관계인이 많은 것 등은 금전 지급을 목적으로 하는 채권에 대한 집행과 동일한 점 등을 참작하여 볼 때 민사집행규칙 제175조 제2항은 직접적으로 관할법원을 정한 것이 아니라 제2차적인 관할에 대한 보충규정이며, 압류되어야 하는 그 밖의 재산권의 소재지에 대한 간주규정이라고 해석되고 있다.¹³⁾ 그러므로 제1차적으로는 여전히 채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 관할권을 가진다고 보아야 할 것이다.¹⁴⁾

IV. 가압류법원의 관할

채권이 가압류된 후 본압류로 이전되는 경우에는 가압류를 명한 법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 제224조 제3항).

13) 東京地裁(債權執行等手續研究會(주9), 5.

14) 이와 같이 해석한 결과, 평가 및 환가할 때에 집행법원과 재산권 소재지가 원격지에 있어 불합리가 생기는 경우도 있을 수 있지만, 채무자의 방어권을 고려하면 어쩔 수 없다고 생각해야 할 것이다.

민사집행법 제정 전에는 위와 같은 규정이 없어서, 채권이 가압류된 다음에 본압류로 이전되는 경우에 가압류법원과 다른 법원이 본압류의 집행법원이 되는 경우가 적지 않았고, 이때에 본압류의 집행법원으로서 가압류결정과 그 송달 여부, 피보전권리의 내용 등을 확인하기 위해서는 가압류법원으로부터 그 기록을 송부받는 것이 원칙일 것인데,¹⁵⁾ 이러한 절차로 인하여 상당한 시간과 비용이 소요될 것임은 명백하였던 바, 위 규정의 신설에 의해 본압류법원은 간편하게 그 법원에 보관되어 있는 가압류기록을 확인할 수 있게 되었다. 다만 여러 건의 가압류가 경합되어 있어서 배당절차에 들어가는 경우에는 여전히 나머지 가압류기록은 송부받아야 할 것이다.

이 관할법원은 지방법원으로 되어 있으므로 고등법원이나 지방법원 합의부 등이 가압류를 한 경우에는 지방법원 단독판사가 이 규정에 의한 관할법원이 된다.

V. 관할권 유무의 심리

1. 관할권 유무의 직권조사

신청된 채권집행에 대하여 법원에 관할권이 있는가 아닌가에 대하여는 법원이 직권으로 조사해야 한다. 사물관할 및 토지관할의 쌍방에 대하여 관할권이 있는 것이 집행법원으로서 압류명령을 발령할 수 있는 전제조건이기 때문이다.

가. 채무자가 개인인 경우의 보통재판적이 문제로 되는 때

채권집행의 신청을 받은 법원은 위와 같이 스스로 관할권이 있는가 아닌가에 대한 판단을 해야 하지만, 집행권원에 표시된 주소와 채권집행의 신청서에 기재된 주소가 동일한 때에는 특단의 자료가 첨부되어 있지 않아도 그 증명이 있는 것으로 처리해도 될 것이다.

집행권원상의 표시와 신청서의 기재가 틀린 경우에는 개인에 있어서는 주민등록등초본 또는 채권자등의 신청서에 의해 이 관계에 대한 증명이 없는 한 압류명령을 발령해서는 안된다.

주소 등에 변동이 있는 경우의 증명방법으로서 주민등록초본이 적격이지만, 주민등록초본의 주소 이외의 장소를 생활의 본거지로 하고 있는 때(주소이전의 신고가

15) 실무상으로는 채권자로부터 가압류결정서 사본, 가압류결정 송달증명서 등을 제출받아 확인하고 있었다고 보여진다.

늦은 경우를 그 예로 들 수 있지만, 채무자가 집행을 면탈하고자 고의로 신고를 지연시키는 경우도 있을 수 있다)에는, 그 사실의 증명에 관하여 채권자 등의 신청서 등에 의해 판단하는 수밖에 없다. 이러한 관할 유무의 판단을 위해 필요하다면 신청본인이나 신청회사의 종업원등을 심문할 수도 있을 것이다. 이와 같은 관할권 유무의 증거조사로서의 심문은, 이론적으로는 압류명령 자체의 것이 아니므로 민사집행법 제226조¹⁶⁾의 적용이 없지만, 압류명령을 채무자 및 제3채무자에 알리지 않고 발령한다고 하는 위 조항의 취지를 감안하면, 이 관할권 유무의 조사를 위해서 채무자 또는 제3채무자를 심문하는 것은 상당하지 않다고 본다.¹⁷⁾

나. 채무자가 법인 기타 사단·재단인 경우의 보통재판적이 문제로 되는 때

채무자가 법인등인 경우에도 신청을 하는 법원에 관할권이 있다는 것의 증명이 필요하므로 채권자는 주된 사무소 또는 영업소 소재지를 관할하는 법원에 대하여 신청을 한 경우에는 관할지역 내에 주된 사무소 또는 영업소가 있음을 증명해야 하지만, 이러한 것은 등기사항으로 되어 있으므로 그 등기된 사무소 등을 주된 사무소 등으로 신청한 때에는 그 등기사항일부증명서를 제출하면 족하다.

이에 대해, 그 외의 장소가 주된 사무소등이라고 신청한 때에는 그 사실을 증명해야 하고, 그 증명을 위해 채권자 또는 채권자의 종업원 그 밖의 자의 진술서 등에 의하는 경우도 있을 것이고 또 필요하다면 앞서 본 것과 같이 이러한 자를 심문하는 것도 가능할 것이다.

또한 법인 등에 주된 사무소 등이 없는 경우에는, 주된 업무담당자의 주소 등에 채무자의 보통재판적이 있는 것으로 되지만, 이것을 신청한 때에는 법인 등에 주된 사무소등이 없는 것, 특정한 자가 주된 업무담당자인 것(이러한 것은 일반적으로 등기사항으로 되어 있다), 그 자의 주소 등이 신청을 한 법원의 관할지역 내에 소재하는 것 등을 증명해야 한다. 그 증명방법은 전술한 것과 같다.

다. 물건의 소재지가 문제로 되는 때

물건의 인도청구권에 대한 압류 신청을 하는 경우에 채무자에게 보통재판적이 없는 때는 목적물 소재지를 관할하는 지방법원이 집행법원으로 되는 것이므로 물건의 소재지 지방법원에 채권집행의 신청을 하는 때에는 채무자에게 보통재판적이 없는 것 및 물건이 신청을 하고 있는 법원의 관할구역 내에 소재하는 것 등을 증명

16) 민사집행법 제226조 [심문의 생략] 압류명령은 제3채무자와 채무자를 심문하지 아니하고 한다.

17) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 93.

해야 한다. 그 증명방법, 집행법원의 심문이 가능한 것 등은 전술한 것과 동일하다.

라. 담보물의 소재지가 문제로 되는 때

담보물 소재지의 지방법원에 관할이 인정되는 것은 채무자의 보통재판적이 없는 것, 압류채권이 물상담보권에 의해 담보되어 있는 채권으로서 그 목적물이 신청을 하고 있는 지방법원의 관할 내에 소재하는 것 등이 요건으로 되어 있으므로 신청채권자는 이러한 것을 증명해야 하고, 그 증명방법이나 필요가 있으면 법원이 심문할 수 있다는 것 등은 전술한 대로이다.

2. 관할의 존재시기

가. 관할권의 존재시기 - 신청시

신청된 채권집행에 대한 관할권은 신청시에 존재해야 하지만(민소 제33조 준용), 신청시에 존재하지 않더라도 발령시에 존재하면 족하다.¹⁸⁾

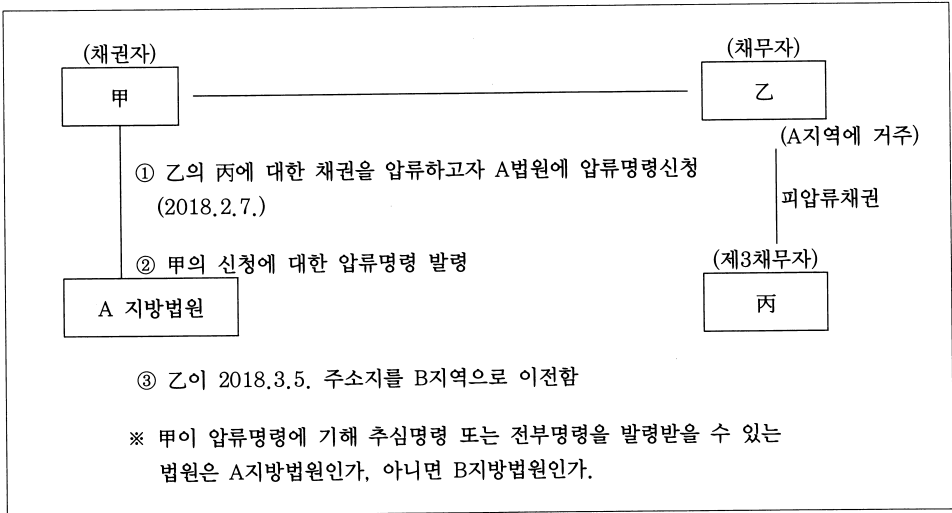
채권집행의 압류명령에 대하여는 신청시로부터 압류명령발령시까지 사이에 그다지 시간이 걸리지 않으므로 문제로 되는 일은 거의 없지만, 사안에 따라서는 그것에 장기간을 요하고 또 채무자 주소의 변경 등이 행하여지는 사태도 예상할 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 경우를 생각하고 또한 채권집행의 특수성을 감안하여 신청시가 아니라 압류명령 발령시에 관할권이 존재해야 한다고 해석하는 견해도 있다.¹⁹⁾

그러나 강제집행을 받는 것을 회피하기 위해서 주소 등을 전전 혹은 이동시킨 채무자도 있을 수 있음을 고려한다면 집행실무상 위 견해는 바람직하지 않다고 본다. 즉 압류명령 신청이 있었음을 알게 된 채무자가 압류명령발령까지 사이에 주소를 이전한 다음 그것을 이유로 압류명령에 대한 즉시항고를 하여 압류명령의 취소를 얻을 수 있다고 한다면 부당하기 때문이다.

18) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 95.

19) 中野貞一郎, 民事執行法(下), 靑林書院新社(1983), 520면; 鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 위 注解民事執行法(4), 399.

나. 압류명령 발령 후 채무자 주소가 변동된 경우



위 사례와 같이 압류명령을 발령한 후 채무자의 주소 등이 변경된 경우에, 그 이후 추심명령 또는 전부명령을 발할 수 있는 법원은 압류명령을 발한 법원인가, 아니면 그에 불구하고 새로운 채무자의 주소 등의 地를 관할하는 법원인가가 문제로 될 수 있다.

이에 대하여 구 민사소송법에서는 압류명령과 추심, 전부명령 및 특별현금화방법을 명하는 현금화처분이 각각 1개의 집행행위를 구하는 신청이라는 이유로 각 신청시를 기준으로 하여 집행법원을 정하고, 압류명령과 별도로 신청을 하는 때에는 압류명령의 발령법원과 다른 법원이 관할하는 경우가 있다는 견해와 현금화처분도 압류명령을 전제로 하는 것이고 또 사건기록의 보존·정리면에서도 압류명령을 발령한 법원에서 현금화처분을 하게 하는 것이 합리적이라는 등의 이유로 관할법원을 고정하여야 한다는 견해가 있었던 것으로 보이는데, 민사집행법의 해석으로서도 문언상으로는 두 가지 해석이 모두 가능하지만, 집행법원의 관할이 변동된다고 한다면 조문의 순서는 먼저 집행법원에 관한 규정(민집 제224조)을 정하고, 그 다음에 절차의 순서에 따라 집행법원이 압류명령을 발하는 것, 현금화처분을 명하는 것을 대등하게 나열하여 규정함이 합리적인데도 민사집행법 제223조는 채권집행이 압류명령에 의해 개시된다고 하여 채권집행이라는 절차의 단서를 정하고, 그 뒤의 발전을 예정하여 다음 조에서 채권집행의 관할법원을 정하고 있는 것은 관할의 고정을 예정하고 있는 것으로 볼 수 있다.²⁰⁾ 따라서 압류명령 이후에 따로이 추심명령, 전부명령을 신청하는 경우에도 당

20) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 315-316.

초 압류명령의 발령법원에 관할이 있게 되므로 위 사례의 경우 여전히 A법원에 관할이 있다고 볼 것이다.

VI. 관할위반의 재판

1. 사물관할 위반의 경우 등

채권집행을 개시시킨 채권압류명령도 법원의 재판(결정)에 의해야 하므로 법원이외의 기관(예컨대, 집행관이나 법원사무관등) 명의로 된 때에는 압류명령은 당연히 무효로서 어떠한 절차를 거칠 필요도 없이 효력이 생기지 않는다.

그러나 외형상 압류명령이 존재하므로 즉시항고의 신청이 있으면 항고법원은(이 경우에는 원심이 없으므로 재도의 고안도 없다), 압류명령을 취소해야 한다.

채권집행은 지방법원이 집행법원으로 되므로(민집 제244조 제1항), 다른 고등법원 또는 가정법원이 압류명령을 발하는 것은 허용되지 않는다. 그러나 잘못하여 이러한 지방법원 외의 법원에 있어서 압류명령이 발하여진 경우에는 그 압류명령의 효력을 어떻게 보아야 하는가에 대하여 설이 나뉘어진다.

그 형식을 중시하는 견해²¹⁾는 이를 무효라고 봄에 대해, 법원이 판단한 것임을 중시하여 무효는 아니고 단지 취소할 수 있다고 보는 견해도 있다.²²⁾ 법원이 재판을 한 것인 이상, 당연히무효라고 보는 것은 상당하지 않으므로 후자의 견해가 타당하다.

채권집행의 신청을 각하한 재판에 대하여 항고가 있고 그 항고심에서 원심각하 재판을 부당하다고 취소한 다음 압류명령을 발한 경우에는, 관할위반의 문제가 생기지 않음은 앞서 본 대로이다.

2. 토지관할 위반의 경우

토지관할이 없는 지방법원에 채권집행의 신청이 있었던 때는 신청을 받은 법원은 관할법원이 자료에서 보아 명확한 때에는 사건을 관할법원에 이송하고(민소 제34조 제1항), 관할법원이 명확하지 않은 때에는 보정을 명한 후 응하지 않을 경우 그 신청을 각하해야 한다.

그러나 토지관할이 없는 데도 잘못하여 압류명령이 발하여진 때에는 압류명령의

21) 松岡義正, 強制執行要論(中), 清水書店(1935), 871.

22) 中野貞一郎(주19), 520.

효과가 어떻게 되는가가 문제로 된다.

이에 대하여, 다른 견해²³⁾가 있을 수 있지만, 채권집행에 있어서 토지관할이 전속관할로 되어 있다(민집 제21조)고 해도 이는 이해관계인의 이익조정의 관점에서 정해져 있는 것이므로 관계인이 이에 대해 불복하지 않으면 절차 수행을 긍정해도 좋다고 본다.²⁴⁾ 따라서 관할권이 없는 법원에서 압류명령이 발하여진 경우에는 관할권이 없다는 취지를 압류명령에 대한 즉시항고 중에 주장할 수 있다고 해석해야 한다.

VII. 이송의 재판

1. 관할위반에 의한 이송

민사집행절차에서 정하고 있는 법원의 관할은 전속으로 되어 있고(민집 제21조), 합외관할(민소 제29조), 변론관할(민소 제30조)등의 규정의 적용이 없어서(민소 제31조), 관할권을 가지지 않는 법원이 채권집행개시를 위한 압류명령을 발할 수 없으므로 가 경우 관할법원이 자료로부터 명확한 때는 당해 관할법원에 사건을 이송하고(민소 제34조 제1항), 그것이 명확하지 않은 때는 보정을 명한 후 응하지 않을 경우 채권집행의 신청을 각하해야 한다.

이 관할 유무는 신청시에 필요하지만(민소 제33조의 준용), 신청시에 없더라도 압류명령 발부시에 있으면 관할위반의 문제는 생기지 않는다.

2. 관할법원간의 사건의 이송

가. 채권집행신청 당시에 있어서 관할법원의 경합

채권집행신청을 하는 경우에도 관할하는 지방법원이 수개 존재하고 그 가운데 1개에 채권자가 채권집행을 하는 경우가 있을 수 있다(예를 들어, 甲이 채권집행신청을 함에 있어 채무자에 대한 관할법원이 A, B 두 군데가 있는데 甲이 A 관할법원에 신청을 한 경우).

이 경우에 신청을 받은 법원은 사건에 대해 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위해서 다른 관할법원에서 사건을 처리하는 편이 바람직하다고 판단되는 때에는 사건을

23) 松岡義正(주21), 871.(이 경우에도 압류명령은 무효라고 해석하는 견해이다)

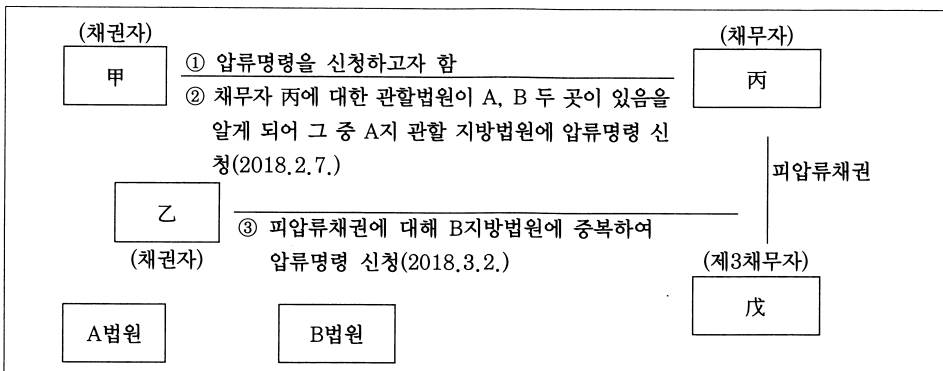
24) 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 269.; 宮脇幸彦, 強制執行法(各論), 有斐閣(1978), 43.; 兼子一, 増補強制執行法, 酒井書店(1979), 17.

다른 관할법원에 이송할 수 있다고 본다(민소 제35조의 준용). 그리고 이러한 이송의 재판은 그것이 압류명령을 발하기 전에 되든, 압류명령을 발한 후에 되든 모두 유효하다.

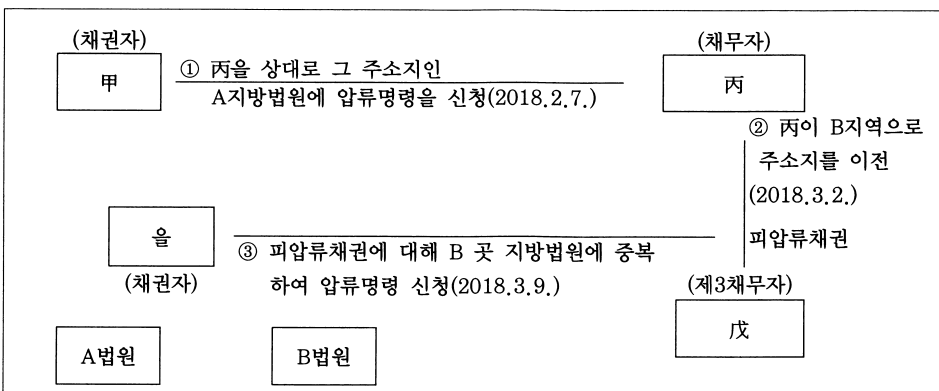
그러나 다른 한편, 채권집행에 있어서는 신청을 받은 법원 이외의 법원에서 사건을 취급하는 편이 사건의 진행 등에 현저한 효과가 기대되는 경우란 거의 있지 않으므로 채권집행신청 당시에 집행법원으로 될 수 있는 법원이 수개 존재하고 또 그 사이에서 이송의 재판을 하는 것이 이론적으로는 가능하다 해도 실제상 그 필요성은 대부분 없을 것이다.

나. 채권집행의 신청이 경합한 경우에 집행법원이 다른 때

[사례1]



[사례2]



채권집행에 있어서 동일채권에 대하여 중복하여 압류명령이 발하여지는 것이 예정되어 있는 경우(민집 제235조 제1항, 제248조 제3항 등), 만일 동일한 집행법원에 사건이 계속하는 때에는 법원의 내부적 절차로 쌍방 사건의 조정(특히 배당등 절차)이 가능하지만, 동일채권에 대하여 수개의 집행법원이 존재하고 상호 절차를 그대로 진행시키는 때에는 상호 절차의 조정(특히 배당등 절차)이 행해지지 않아 채권자 사이에 이해의 불균형이 생길 수 있다.

위 사례에서 [사례1]의 경우에는 위에서 본 바와 같이 민소법 제35조를 준용하여 현저한 손해나 지연을 방지하기 위한 이송이 가능하다고 볼 수 있다.²⁵⁾

하지만 위 [사례2]의 경우에는 나중에 압류명령을 발한 B 집행법원과 이전의 A 집행법원 사이에서는 관할이 경합하지 않고, 또 이러한 경우는 위와 같은 민사소송법 제35조가 예정하고 있는 바도 아니어서 그에 따른 이송도 할 수 없게 되므로 쌍방 절차의 조정이 행해지지 않아 결국 「빠른 者가 승리」 하는 결과를 가져올 수가 있는 것이다.

이와 같은 이유로 집행법원이 다르게 경우에도 쌍방 절차를 조정할 필요가 있기 때문에 서로 사건을 이송할 수 있도록 명문으로 규정함이 바람직하다고 생각한다.

이러한 경우에, 위 이송재판을 어느 법원이 하는가에 대하여는 법원의 재량에 의할 것이나, 일반적으로 나중에 압류명령을 발한 집행법원의 사건이 최초로 압류명령을 발한 집행법원에 이송하는 식으로 하면 될 것이다.

왜냐하면, 압류가 된 채권에 대하여 다시 압류명령이 있는 경우(민집 제235조에 의해 압류가 경합하고 있지 않은 경우, 즉 피압류채권의 권면액은 1,000만 원이지만 어느 채권자는 400만 원 부분만을 압류하고, 다른 채권자는 500만 원 부분만을 압류한 경우를 포함한다)에는 제3채무자가 공탁을 한 후 최초로 압류명령을 송달한 법원에 대하여 사유신고를 해야 하는 것으로 되어 있기 때문이다(민집규 제172조 제3항).

Ⅷ. 사법보좌관제도

1. 의의

법원조직법의 개정(2005. 3. 24. 법률 제7402호)에 따라 사법보좌관 제도가 도

25) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 100.

입되어 2005. 7. 1.부터 시행되고 있다. 사법보좌관은 법률과 대법원규칙이 정하는 바에 따라 법원의 업무 중 실질적 쟁송에 해당하지 아니하는 부수적 업무와 공증적 성격의 업무를 담당하는 일종의 사법관이다.

법원조직법 제54조는, 대법원과 각급 법원에 사법보좌관을 둘 수 있고(제1항), 사법보좌관은 민사소송법, 민사집행법 등에 규정된 법원의 사무 중 대법원규칙이 정하는 업무를 할 수 있으며(제2항), 사법보좌관은 법관의 감독을 받아 업무를 수행하며 사법보좌관의 처분에 대하여는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 법원에 대하여 이의신청을 할 수 있고(제3항), 사법보좌관은 법원사무관 또는 등기사무관 이상 직급으로 5년 이상 근무한 자, 법원주사보 또는 등기주사보 이상 직급으로 10년 이상 근무한 자 중 대법원규칙이 정하는 자로 하며, 사법보좌관의 직제 및 인원 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정하는 것으로(제5항) 규정하고 있다. 그리고 사법보좌관 규칙은 법원조직법 제54조의 규정에 따라 사법보좌관이 할 수 있는 업무의 범위, 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청, 업무의 감독, 사법보좌관의 자격 및 선발, 직제, 교육 그 밖에 필요한 사항을 정하고 있다.

사법보좌관 제도가 도입됨으로써 종전에 판사가 수행하던 대부분의 집행법원의 사무는 사법보좌관이 처리하고 있고, 이에 따라 집행절차에 있어서의 불복방법 중 즉시항고 등에 많은 변화가 일어나게 되었다

2. 사법보좌관의 업무

가. 업무의 내용

사법보좌관이 행할 수 있는 업무는 법원조직법 제54조 제2항, 사법보좌관규칙 제2조 제1항에서 규정하고 있는데, 그 중 민사집행절차에 관한 것은 다음과 같다.

- ① 집행문부여 명령(민집 제32조, 제35조, 제57조)에 관한 법원의 사무
- ② 채무불이행자명부 등재절차(민집 제70조 내지 제73조)에서의 법원의 사무
- ③ 재산조회절차(민집 제74조, 제75조 제1항)에서의 법원의 사무
- ④ 부동산에 대한 강제경매절차(민집 제78조 내지 제162조)와 자동차·건설기계·소형선박에 대한 강제경매절차(민집 제187조)에서의 법원의 사무[다만, ㉞ 경매개시결정에 대한 이의신청에 대한 재판(민집 제86조), ㉟ 부동산의 인도명령 및 관리명령(민집 제136조)에 해당하는 사무는 제외]
- ⑤ 유체동산집행 중 압류물의 인도명령(민집 제193조)과 특별현금화명령(민집

제214조)에 관한 법원의 사무

⑥ 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차(민집 제223조 내지 제251조)에서의 법원의 사무[다만, ㉠ 채권추심액의 제한허가(민집 제232조 제1항 단서), ㉡ 특별현금화명령(민집 제241조 제1항), ㉢ 압류금지채권의 범위변경(민집 제246조 제2항 내지 제4항)에 해당하는 사무는 제외]

⑦ 동산집행의 배당절차(민집 제252조 내지 제256조)에 관한 법원의 사무

⑧ 부동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차(민집 제264조 내지 제268조)와 자동차·건설기계·소형선박을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차(민집 제270조)에서의 법원의 사무(다만, 민집 제86조, 제136조의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑨ 유체동산, 채권과 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행절차(민집 제271조 내지 제273조)에 관한 법원의 사무 가운데 민사집행법 제193조, 제214조, 제223조 내지 제251조, 제252조 내지 제256조의 규정이 준용되는 사무(다만, 민집 제232조 제1항 단서, 제241조 제1항, 제246조 제2항 내지 제4항의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑩ 유치권 등에 의한 경매절차(민집 제274조)에서의 법원의 사무 가운데 민사집행법 제264조 내지 제268조, 제270조, 제271조 내지 제273조의 규정이 준용되는 사무(다만, 민집 제86조, 제136조, 제232조 제1항 단서, 제241조 제1항, 제246조 제2항 내지 제4항의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑪ 부동산에 대한 강제경매절차, 자동차·건설기계·소형선박에 대한 강제경매절차, 유체동산에 대한 강제경매절차, 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차에서 법원의 사무 가운데 집행의 정지 및 제한(민집 제49조), 집행처분의 취소 및 일시유지(민집 제50조)

⑫ 부동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차, 자동차·건설기계·소형선박을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차, 유체동산·채권과 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행절차, 유치권 등에 의한 경매절차에서의 법원의 사무 가운데 경매절차의 정지 및 경매절차의 취소·일시유지(민집 제266조, 제270조, 제272조, 제274조 제1항)

⑬ 본안의 제소명령(민집 제287조 제1항, 제301조, 가소 제63조)

⑭ 가압류·가처분집행의 취소에 관한 법원의 사무

나. 업무의 성격

사법보좌관은 주로 경매 등 민사집행절차에서 실질적 쟁송에 해당하지 않는 비송적 업무와 집행문부여절차와 같은 공증적 성격의 업무 중 법률과 대법원규칙이 위임하는 일부만을 처리하고, 당사자 사이에 다툼이 있는 실질적 쟁송사건인 민·형사상의 일반 사건은 담당하지 않는다.

그리하여 경매절차 가운데에서도 실질적 쟁송에 가까운 부동산의 인도명령 및 관리명령, 채권추심액의 제한허가 등은 사법보좌관의 업무에서 제외되었고, 경매개시 결정에 대한 이의신청 재판은 경매개시결정에 대한 불복절차이므로 당연히 제외되었다. 그리고 가압류·가처분절차 및 그 불복절차는 민사집행법에서 규정하고 있지만, 집행권원이 없는 상태에서 임시로 채무자의 재산을 동결하는 조치를 하는 절차로서 피보전권리의 존부 및 보전의 필요성에 대한 실체적 판단이 필요한 실질적 쟁송에 해당하므로 사법보좌관의 업무에서 제외하였다. 다만, 가압류·가처분 집행을 취소는 쟁송성이 없으므로, 사법보좌관이 담당한다.

다. 업무의 처리

개정된 법원조직법의 시행일자는 2005. 7. 1.이고(부칙 제1항), 법 시행 전에 접수된 사건은 판사가 이를 처리하도록 하고 있으므로(부칙 제2항), 2005. 7. 1. 이후에 접수된 사건만 사법보좌관이 처리할 수 있다. 따라서 2005. 6. 30.까지 접수된 사건은 계속하여 종국시까지 판사가 처리하여야 한다.

3. 사법보좌관의 처분에 대한 불복

가. 서설

1) 법원조직법 제54조 제3항은 “사법보좌관의 처분에 대하여는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 법원에 대하여 이의신청을 할 수 있다.”라는 일반원칙을 선언하고 있다. 이것은 원래 사법보좌관의 업무를 판사가 처리하던 상황에서는 존재하지 않던 ‘이의신청’ 제도를 새로이 설정한 것이다. 즉 판사의 처분에 대하여는 민사소송법이나 민사집행법에 따른 통상의 불복절차에 따르면 그만이나, 사법보좌관의 처분에 대하여는 그 이전의 단계에서 ‘법원에 대하여 이의신청’을 할 수 있도록 하였

다.²⁶⁾

이는 사법보좌관은 법관이 아니므로 사법보좌관의 처분에 대하여 법관이 심사할 수 있도록 함으로써 헌법 제27조 제1항의 “모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.”라는 규정과 헌법 제101조 제1항의 “사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.”라는 규정에 사법보좌관 제도를 합치시키려는 조치이다.

2) 위 법원조직법 제54조 제3항의 위임에 따라, 사법보좌관규칙 제3조는 “지급 명령 등의 처분에 대한 불복”을, 위 규칙 제4조는 “즉시항고 등의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청”을, 위 규칙 제5조는 “배당표에 대한 이의신청”을 순차로 규정함으로써 다음과 같은 세 가지 유형을 정해두고 있다.

유 형	내 용
제1유형 (사보규 제3조)	이는 개별 법률에서 해당 처분에 대한 불복방법이 이의신청이고, 그 이의신청에 대하여 같은 심급의 판사가 심사하도록 규정하고 있는 경우를 말한다. 이때에는 해당 법률에서 규정하는 이의신청 절차를 그대로 따르도록 하였고, 이 절차는 해당 처분을 판사가 한 경우와 원칙적으로 같다. 이것은 개별 법률에서 인정하는 불복수단과 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청이라는 이중의 불복방법을 두어서 생길 수 있는 절차상의 지연과 혼란을 막기 위한 것이다. 이에 따라 규칙 제3조는 그 용어도 ‘이의신청’이라는 용어 대신 ‘불복’이라는 용어를 사용하였

26) 이의신청 제도는 독일의 사법보좌관법에 그 입법적인 근거를 두고 있다. 즉 1975년의 독일 사법보좌관법은 제11조를 두어 사법보좌관의 처분에 대한 법적 구제수단을 마련하면서, 상급심 법원에 의해 재심사가 이루어지는 ‘항고(Beschwerde)’가 아니라, 같은 심급의 같은 법원에서 법원에 의한 재심사가 이루어지는 ‘이의(Erinnerung)’ 제도를 채택하였고, 이것은 사법보좌관의 재판에 대하여도 법관의 재판에서와 같은 불복방법을 인정해야 한다는 사법보좌관협회의 요구를 받아들이지 않은 것이었다[최완주, “유럽의 사법보좌관제도”, 법원일반직공무원 및 사법보좌관제도 연구(1996), 353.; 정선주, “독일 사법보좌관의 지위와 제3차 사법보좌관법 개정법”, 비교사법 제8권 제1호(통권 제14호, 2001. 6.), 619.]. 그러나 그 후 1998년의 제3차 사법보좌관법 개정제에 의하여 사법보좌관의 판단에 불복하는 권리구제제도는 완전히 새로운 체계를 갖추게 되어 종전의 ‘이의’는 폐지되었고, 일반적인 상소제도가 도입되어 상급법원에 항소하도록 하였다. 이러한 변화는 동일한 심급에서 2개의 사법기구, 즉 사법보좌관과 법관이 권리구제제도를 다루어서는 안 된다는 입장에 근거한 것으로서, 일반적인 상소제도가 인정되지 않는 경우에는 이의가 인정되고, 위 이의에 대하여는 사법보좌관이 스스로 자신의 재판을 결정할 수 있으며, 그렇지 아니한 경우에는 법관이 최종적으로 판단하도록 한 것이다[정선주, 620-621.].

	다. ²⁷⁾
제2유형 (사보규 제4조)	이는 사법보좌관의 처분 중 그 처분을 판사가 한 경우라면 항고, 즉 시항고 또는 특별항고의 대상이 되는 처분을 사법보좌관이 한 경우를 지칭하고, 이에 그에 대한 불복은 '이의신청'의 방법에 의하도록 하였다. 이에 대하여는 일단 같은 심급의 판사가 심사하여 직접 처리하거나 항고법원에 송부하는 등의 절차를 밟게 된다. 동일한 심급 내에 별도로 '이의신청' 절차를 마련한 것으로서, 법원조직법 제54조 제3항이 예정하고 있는 '이의신청'에 해당한다. 이것은 같은 심급 내에서 재심사가 이루어지는 일종의 속심이라 할 수 있다.
제3유형 (사보규 제5조)	이는 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 불복방법에 관한 것이다. 민사집행법상 본래의 불복방법이 이의이지만, 그 이의신청에 대하여 규칙 제3조의 경우와 같이 같은 심급의 판사가 다시 심사하도록 규정한 절차가 없어 제1유형과 다른 뿐만 아니라, 이의신청이 이유 없는 경우 사건을 항고법원에 송부하는 것이 아니라, 같은 심급의 판사가 최종적으로 배당표를 작성하고 이에 대하여 다시 이의 및 배당이의 소송 등을 하게 되는 점에서 제2유형과도 다르므로, 이를 별도로 규정하게 되었다. 이것도 역시 동일한 심급 내에 별도로 '이의신청' 절차를 마련한 것으로서, 법원조직법 제54조 제3항이 예정하는 '이의신청'에 해당한다. 또한 이것도 같은 심급 내에서 재심사가 이루어지는 일종의 속심이라 할 수 있다.

나. 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로서 즉시항고할 수 없는 것에 대한 이의신청(사보규 제3조 제2호)

1) 민사집행법은 집행법원의 집행절차에 관한 재판 중, 특별한 규정이 있어야만 즉시항고에 의하여 불복하도록 하고(제15조 제1항), 즉시항고를 할 수 없는 것에 대하여는 '집행에 관한 이의신청'으로 불복하도록 하고 있다(제16조 제1항).

이러한 것들의 예로는, ① 부동산경매절차에서 경매법원이 대금납부기한을 지정하거나 지정된 기한을 취소하는 등의 결정, ② 공탁사유신고를 각하한 결정(민집 제248조 제4항 참조), ③ 경매절차를 취소할 사유가 있음에도 집행법원이 취소결정을 하지 않는 경우, ④ 가처분결정 취소판결 정본의 제출에 따른 간접강제결정 취소결정, ⑤ 민사집행법 제50조의 집행취소결정, ⑥ 경매절차에서 배당기일에 불출석한 채

27) 따라서 엄밀한 의미에서 규칙 제3조는 법원조직법 제54조 제3항이 예정하는 별도의 '이의신청'에는 해당하지 않는다고 볼 수 있다.

무자가 자신에게 공탁된 배당 잔여금의 출급을 위하여 집행법원에 지급위탁서의 송부와 자격증명서의 교부를 신청하였다가 거절당한 경우, ⑦ 서로 모순 저촉되는 점유이전금지가처분 집행이 경합된 경우, ⑧ 집행법원의 착오에 의한 등기촉탁에 의하여 가압류기입등기가 말소된 때 가압류채권자의 회복등기 촉탁신청을 거절한 경우, ⑨ 가처분해제신청서가 위조되었다고 주장하는 가처분채권자가 법원의 촉탁에 의하여 말소된 가처분기입등기의 말소회복을 구하는 경우 등이 있다.

2) 통상 판사가 위와 같은 처분을 하게 되면 이에 불복하는 이해관계인이 집행에 관한 이의신청(민집 제16조 제1항)을 하고, 그 판사가 다시 이를 판단하게 되는 것이나, 사법보좌관규칙 제3조 제2호는 사법보좌관이 위 처분을 하였을 경우 이해관계인이 '집행에 관한 이의신청'을 하고, 이에 대한 재판은 판사가 담당하도록 하였다. 판사는 이의신청에 대하여 결정으로 재판한다. 이의신청이 부적법하다고 인정한 때에는 그 신청을 각하하여야 하고, 이유가 없을 때에는 이의신청을 기각한다. 이의신청의 사유가 있다고 인정한 때에는 대상이 되는 집행처분의 내용에 맞추어 적당한 취지의 결정을 해야 한다. 즉 개개의 집행처분을 취소하고 새로운 처분을 한다는 취지를 선언한다.

3) 경매개시결정에 대한 이의신청(민집 제86조)은 그 성질상 집행에 관한 이의신청의 일종이지만, 사법보좌관규칙 제2조 제1항 제7호 가목은 사법보좌관의 업무에서 '경매개시결정에 대한 이의신청' 재판을 제외함으로써 판사가 이를 담당하도록 하였다. 따라서 경매개시결정은 위 규칙 제3조 제2호의 '집행법원의 집행절차에 관한 재판으로 즉시항고할 수 없는 것'에 해당하지만, 사법보좌관이 경매개시결정을 하였을 경우 이해관계인이 경매개시결정에 대한 이의신청을 하면 이에 대한 재판은 판사가 담당한다.

다. 즉시항고 등의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청(사보규 제4조)

1) 이의신청 대상

가) 사법보좌관규칙 제4조가 규정하는 이의신청의 대상은 "사법보좌관의 처분 중 단독 판사 또는 합의부(이하, '단독판사등'이라고 한다)가 처리하는 경우 항고, 즉시항고 또는 특별항고의 대상이 되는 처분'이다(사보규 제4조 제1항).

나) 단독판사등이 처리하는 경우 항고(일반항고)의 대상이 되는 처분으로는 제소명령 신청을 기각하거나 각하한 결정을 들수 있고, 즉시항고의 대상이 되는 처분으로는 소송비용액·집행비용액 확정절차상의 사무, 독촉절차상의 사무 중 이의신청 각하결정과 지급명령신청서 각하결정, 공시최고불허가결정, 채무불이행자명부 등재신청에 대한 재

판, 경매신청각·각하결정, 매각허가여부결정, 압류물 인도명령, 압류명령·추심명령·전부명령의 신청에 관한 재판, 해방공탁을 이유로 한 가압류집행취소결정, 경정재판 등을 들 수 있으며, 특별항고의 대상이 되는 처분으로는, 독촉절차상의 사무 중 지급명령신청 각하결정과 소송절차회부결정, 동산집행절차에서 특별현금화명령 등이 있다.

2) 이의신청 방식

가) 이의신청은 대상이 되는 처분의 표시와 그 처분에 대한 이의신청 취지를 밝히는 방법으로 사법보좌관에게 하여야 하고, 해당 법률에서 불복방법을 서면으로 한정한 때에는 이들 사항을 적은 서면을 사법보좌관에게 제출하여야 한다(사보규 제4조 제2항).²⁸⁾ 29)

단독판사등이 처리하는 경우 즉시항고 또는 특별항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청은 그 처분을 고지받은 날로부터 7일 이내에 하여야 하고, 이 기간은 불변기간이다(사보규 제4조 제3항). 이의신청에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 해당 법률에서 정하고 있는 불복절차에 관한 규정이 준용되므로(사보규 제4조 제10항), 소송행위의 추후보완에 관한 민사소송법 제173조의 규정과 부가기간에 관한 민사소송법 제172조 제2항, 제3항이 준용된다. 단독판사등이 처리하는 경우 통상항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청은 기간에 제한 없이 처분의 취소를 구할 이익이 있는 한 언제든지 할 수 있다.

나) 사법보좌관에 대하여 이의신청을 하는 단계에서는 민사소송 등 인지법에 따른 인지를 붙일 필요가 없다(사보규 제4조 제4항).³⁰⁾ 당사자가 사법보좌관의 처분에

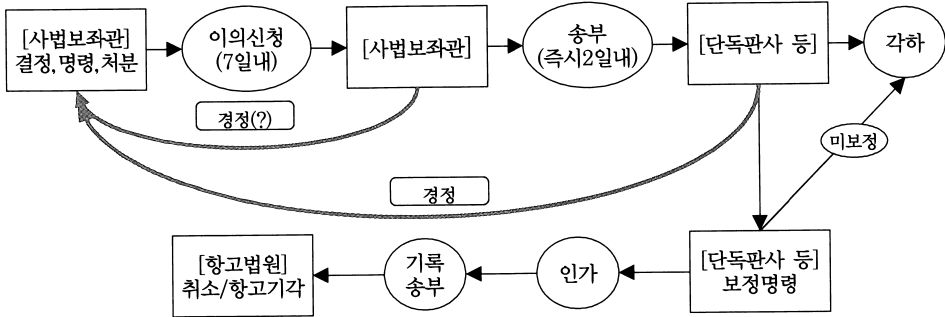
28) 이의신청을 사법보좌관에게 하도록 한 것은 사법보좌관 스스로 재도의 고안으로써 자신이 한 처분을 정정할 기회를 주기 위한 것이다.

29) 별지 [2-1] 사법보좌관 처분에 대한 이의신청서 참조(제2장 말미 수록)

30) 종래 사법보좌관규칙 제4조 제4항이 즉시항고 등의 대상이 되는 사법보좌관의 처분에 대하여 이의신청을 할 때에 「민사소송 등 인지법」 또는 해당 법률에서 정하는 인지, 보증제공서류 등을 붙일 필요가 없다고 규정하고 있던 것과 관련하여, 이에 따를 경우 ① 판사가 처리하면 즉시항고의 대상이 되는 처분을 사법보좌관이 행하는 경우, 이의신청인은 이의신청서에 그 사유를 기재하지 않아도 되고, 단독판사등이 사법보좌관의 처분에 잘못이 없다고 보고 이를 인가한 경우에도 도로 항고이유서 등의 제출에 대한 보장을 명하여야 하는바, 이는 항고장 제출일로부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하도록 한 민사집행법 제15조 제3항의 취지가 약화되고 이로 인해 집행절차의 신속성이 저해되는 문제가 발생하는 점, ② 현재 대부분의 부동산 경매절차는 사법보좌관이 처리하는 상황에서, 사법보좌관이 내린 매각허가결정에 대한 이의신청을 제기하였고, 기록을 송부받은 법관이 이의신청이 이유 없다고 판단하여 이의신청이 항고로 의제되는 경우에는, 민사집행법 제130조 제4항에도 불구하고 사법보좌관규칙 제4조 제6항 제6호에 따라 보증제공서류(항고보증금 납부 증명서류)를 제출하라는 보정명령을 발하여야 하며, 이로써 매각허가결정에 대해 의례적으로 항고나 이의신청을 하곤 하는 경매절차에서의 채무자나 소유자는 사법보좌관의 매각허가결정에 대한 이의신청을 통해

대하여 즉시항고의 형식으로 불복하더라도 이를 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청으로 보아 처리하여야 한다.

3) 사법보좌관의 사건처리



사법보좌관이 이의신청을 받은 때에는 이의신청사건을 지체 없이 소속법원의 단독 판사등에게 송부하여야 한다(사보규 제4조 제5항). 이때 특별항고의 대상이 되는 결정을 제외하고는 사법보좌관 스스로 재도의 고안으로써 자신이 한 처분을 경정할 수 있다.³¹⁾

대략 1개월 정도의 시간을 벌게 되고, 반면 채권자나 매수인 측에서는, 민사집행법 제130조 제4항의 입법취지에도 불구하고, 약 1달 정도의 절차지연을 감수해야 하는 상황이 벌어지고 있는 점(이는 민사집행법이 무익한 남항고 및 경매절차 지연을 방지하기 위한 조기 항고각하결정의 취지를 무력화시키는 문제를 야기함), ③ 사법보좌관규칙 제4조 제10항은 이의신청에 관해 그 성질에 반하지 않는 한 해당법률에서 정한 불복절차 규정을 준용하도록 규정하고 있고, 위 항고이유서제도나 항고보증금제도는 이의신청절차 자체의 성질에서 비롯된 것이기 보다는 집행절차 자체의 신속성 보장과 남용적 불복을 방지하기 위한 것으로서, 이의신청절차의 성질에 반한다고 보기 어려우므로(즉시)항고에 관한 규정은 그대로 준용되어야 할 것인데도 이를 준용하지 않음으로써 법률의 규정에 반하는 해석을 한다는 지적이 있어 왔다. 이러한 지적에 따라 사법보좌관규칙을 개정하였는바(2014. 9. 1. 대법원규칙 제2552호로 개정, 2015. 3. 23. 시행예정), 그 주요내용은 다음과 같다. 즉 ① 즉시항고 등의 대상이 되는 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청을 할 때 인지 외에 항고절차의 요건이 되는 서류 등은 민사집행법 등의 규정에 따라 제출하도록 하고(개정 사보규 제4조 제4항), ② 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부할 때 인가결정을 이의신청인에게 고지하도록 하며(개정 사보규 제4조 제6항 제5-2호), ③ 사법보좌관의 처분을 인가할 때 항고의 요건이 되는 항고이유서, 항고보증금 등은 보정을 명하지 않고 인지만 보정하도록 명하며 보정하지 않은 때에는 이의신청을 각하하고(개정 사보규 제4조 제6항 제6호), ④ 고지되는 인가결정은 불복대상이 아님을 명시하였다(개정 사보규 제4조 제8항). 또한 ⑤ 민사집행법의 항고절차 등에 관해서는 민사집행법이 준용되고, 사법보좌관규칙이 적용되지 않음을 분명히 하였다(개정 사보규 제4조 제10항).

- 31) 이 경우 사법보좌관 스스로의 경정 가부에 관하여 견해의 대립이 있으나, 실무는 이를 인정하고 있다. 다만 사건을 지체 없이 송부하도록 한 규정의 취지에 비추어 보면, 다만 사건을 지체 없이 송부하도록 한 규정의 취지에 비추어 보면, 이러한 경정은 이의신청 접수일로부터 2일 정도 이내에 신속하게 할 필요가 있을 것이다.

이의신청이 사법보좌관규칙 제4조 제2항의 규정³²⁾에 위배되는 경우에도 단독판사 등이 보정명령을 하고 그 각하 여부를 결정하므로, 사건을 단독판사 등에게 송부하여야 한다.

사법보좌관이 단독판사등에게 이의신청사건을 송부한 이후에는 단독판사등이 이의신청을 각하하거나 사법보좌관의 처분을 인가 또는 경정할 수 있을 뿐 그 사건을 사법보좌관에게 다시 환송하는 제도가 없으므로, 해당 처분에 관한 사법보좌관의 임무는 거기에서 종결한다.

4) 단독판사등의 사건처리

가) 각하결정 : 이의신청사건을 송부받은 단독판사등³³⁾은 이의신청이 사법보좌관규칙 제2항의 규정에 위배되는 경우 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 흠을 보정하도록 명한다(사보규 제4조 제6항 제1호). 이의신청인이 흠을 보정하지 아니하는 때와 이의신청기간을 경과한 때에는 결정으로 이의신청을 각하한다. 이의신청인이 이의신청을 하면서 항고요건을 갖추지 않은 경우, 즉 항고이유서를 제출하지 않은 경우에는 이의신청 각하결정을 하고(민집 제130조 제4항 참조),³⁴⁾ 보증을 제공하지 않은 경우에는 이의신청서 각하결정³⁵⁾ 36)을 한다.³⁷⁾

이 경우 각하결정은 해당법률에 규정된 불복신청에 대한 각하재판으로 본다(사보규 제4조 제6항 제2호). 이 재판에 대하여는 해당법률에서 정한 절차에 따라 불복할 수 있다(사보규 제4조 제6항 제7호). 즉 민사소송법 제443조, 제399조 제3항이나 민집행법 제15조 제8항 등에 따라 즉시항고를 할 수 있다.

나) 이의신청이 이유 있는 경우 : 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 사법보좌관의 처분을 경정한다(사보규 제4조 제6항 제3호). 이 경정은 단독판사등이 사법보좌관의 처분을 심사하여 하는 규칙상의 처분으로서, 사법보좌관이 재도의 고안에

32) 사법보좌관규칙 제4조 제2항 ㉠ 제1항의 규정에 따른 이의신청은 이의신청대상이 되는 처분의 표시와 그 처분에 대한 이의신청 취지를 밝히는 방법으로 사법보좌관에게 하여야 한다. 다만, 제2조 제1항 각 호의 해당법률(이하 이 조 및 제5조에서 “해당법률”이라 한다)에서 이의신청 방법을 서면으로 한정할 때에는 이들 사항을 적은 서면을 사법보좌관에게 제출하여야 한다.

33) 사법보좌관규칙 제4조상의 이의신청 사건을 처리하는 ‘판사’는 ‘단독판사’를 의미하는 것이 아니라 ‘제1심 수소법원’을 의미한다(대법원 2008. 6. 23.자 2007마634 결정).

34) 대법원 2009. 4. 10.자 2009마519 결정; 대법원 2011. 2. 7.자 2011마54 결정

35) 대법원 2011. 4. 14.자 2011마38 결정

36) 별지 [2-3] 이의신청서 각하결정 참조(제2장 말미 수록)

37) 위와 같이 해당 법률에 규정된 절차에 따라 이의신청을 각하하는 경우 별도로 사법보좌관의 처분을 인가해 두어야 하는지 여부에 관하여 해석상 문제가 있으나, 별도로 인가결정을 할 필요가 없다는 견해가 유력하다.

의하여 하는 경정과는 그 성격이 다르다. 즉 이 경우 경정은 처분의 취소·변경을 의미한다.

즉시항고의 대상인 처분에 대한 이의신청이 이유 있다는 것은, 민사소송법 제443조, 제416조, 제417조가 규정하는 “(사법보좌관의 처분을) 정당하지 아니하다고 인정한때” 및 “절차가 법률에 어긋날 때”를 말한다. 사법보좌관의 처분에 법령위반이 있는 경우뿐만 아니라 사실인정을 잘못된 경우에도 그 처분을 경정할 수 있다. 사법보좌관의 처분의 일부만이 부당한 때에는 일부를 취소하고, 나머지를 인가하는 재판을 할 수 있다.

이 재판에 대하여도 해당 법률에서 정한 절차에 따라 불복할 수 있다(사보규 4제조 제6항 제7호). 즉 단독판사등이 한 경정재판이 항고 또는 즉시항고의 대상이면 그 절차에 따라 불복을 하고, 단독판사등이 한 재판이 예컨대 지급명령을 한 것이면 이의신청의 방법으로 불복할 수 있다.

다) 이의신청이 이유 없는 경우 : 사법보좌관의 처분 중 단독판사등이 처리하는 경우 항고 또는 즉시항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부하여야 하고, 이 경우 이의신청은 해당 법률에 의한 항고 또는 즉시항고로 본다(사보규 제4조 제6항 제5호). 위 인가결정은 이의신청인에게 고지한다(사보규 제4조 제6항 제5-2호). 이에 대하여는 불복할 수 없다(사보규 제4조 제8항).

사법보좌관규칙 제4조 제6항 제5호의 경우 이의신청에 민사소송 등 인지법에서 정하는 인지가 붙어 있지 아니한 때에는 상당한 기간을 정하여 이의신청인에게 보정을 명하고, 이의신청인이 이를 보정하지 아니한 때에는 이의신청을 각하(실질상 항고 또는 즉시항고의 각하)한다(사보규 제4조 제6항 제6호).

사법보좌관규칙 제4조 제6항 제2호와 제6호는 모두 이의신청이 형식적 요건을 갖추지 못하여 부적법하다는 이유로 이를 각하하는 것이지만, 제4조 제4항이 이의신청의 방식으로 인지를 붙일 필요가 없다고 규정하고, 또 제4조 제6항 제3호가 그 상태에서 사법보좌관의 처분을 경정할 수 있다고 규정하고 있으므로, 이의신청의 형식적 요건을 ‘이의신청 자체의 방식’과 ‘항고 또는 즉시항고로서의 방식’으로 나누어 이를 각하하는 절차를 달리 규정한 것이다.

위 이의신청 각하재판에 대하여는 해당 법률에서 정한 절차에 따라 불복할 수 있으므로(사보규 제4조 제7항), 민사소송법 제443조, 제399조 제3항 또는 민사집행

법 제15조 제8항, 제130조 제5항에 따라 즉시항고를 할 수 있다.

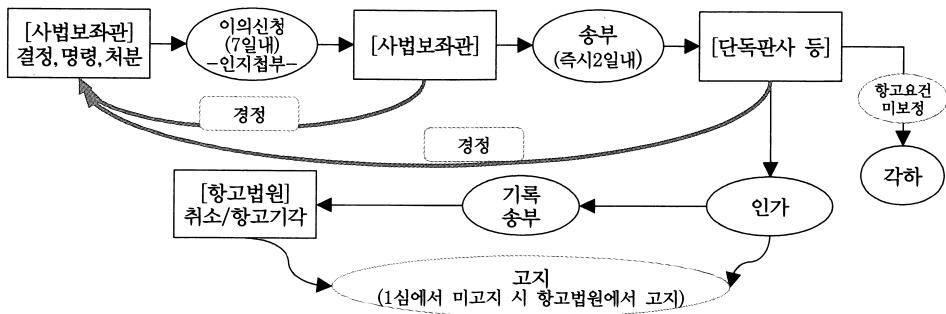
라) 특별항고 대상 처분에 대한 이의신청이 이유 없는 경우 : 사법보좌관의 처분 중 단독판사등이 처리하는 경우 특별항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 결정으로 이의신청을 각하한다(사보규 제4조 제6항 제4호). 이 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다(사보규 제4조 제8항).

특별항고의 대상이 되는 처분은 원래 불복할 수 없는 결정이나 명령으로서 곧바로 확정되는 것이므로, 항고 또는 즉시항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청이 이유 없다고 인정되는 때에 사법보좌관의 처분을 인가하는 것과 달리, 결정으로 이의신청을 각하하도록 한 것이다.

마) 잠정처분 : 판사가 사법보좌관규칙 제4조 제6항에 따라 이의신청 사건을 처리하는 경우에 해당 법률에 규정된 절차에 따라 사법보좌관의 처분의 집행을 정지하거나 그 밖의 필요한 처분을 할 수 있다(사보규 제4조 제6항 본문 후단).

바) 절차의 도해 : 2014. 9. 1. 개정된 사법보좌관규칙에 따라 인가결정의 고지와 그 후속절차를 도해해보면 다음과 같다.

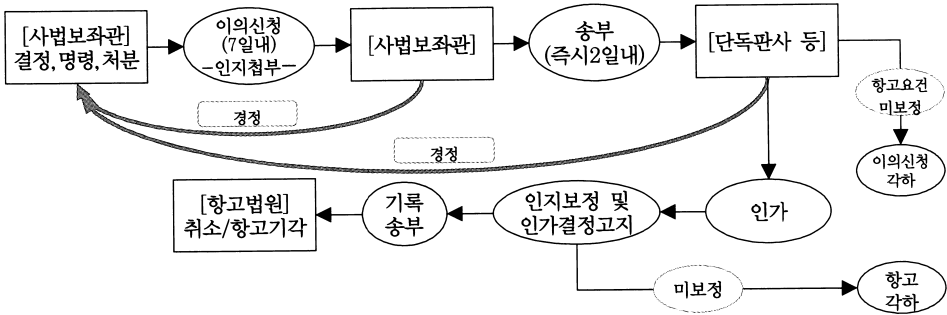
(1) 이의신청 당시에 항고에 관한 인지를 붙인 경우 : 이 경우는 인가결정을 고지(송달)하되, 송달여부와 무관하게 항고법원으로 기록을 송부하고, 항고법원에서 후속고지절차를 진행한다.



(2) 이의신청 당시에 인지를 붙이지 않은 경우 : 이때는 인가결정 전에 보정명령을 함으로써 이의신청인으로 하여금 사실상 항고의사를 확인하던 절차를 거치지 않는다. 인가결정을 한 후, 그 인가결정을 고지하면서 의제된 절차에 따라 항고인지보정명령을 내린다. 인지미보정시에는 이의신청을 각하(실질상 항고 또는 즉시항고의 각하)하고, 인지보정시에는 항고법원으로 기록을 송부한다.

5) 항고법원의 사건처리

사법보좌관의 처분에 대하여는 일반적인 항소제도가 적용되지 않고 별도의 이의신청 제도가 적용되므로, 사법보좌관의 처분 자체는 항고법원의 심판대상이 될 수 없다.



그러므로 ① 단독판사등이 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청이 부적법하다는 이유로 이를 각하하는 재판을 한 경우에는 단독판사등의 각하재판이 항고법원의 심판대상이 된다. ② 단독판사등이 이의신청이 이유 있다고 인정하여 사법보좌관의 처분을 경정한 경우에는 단독판사등의 경정재판 중 항고 또는 즉시항고의 대상이 되는 것은 항고법원의 심판대상이 된다. ③ 단독판사등이 특별항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청이 이유 없다고 인정하여 각하결정을 한 경우에는 단독판사등의 각하결정이 대법원의 심판대상이 된다. ④ 단독판사등이 항고 또는 즉시항고의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청이 이유 없다고 인정하여 사법보좌관의 처분을 인가한 경우에는 단독판사등의 인가처분이 항고법원의 심판대상이 되므로, 이러한 이의신청 사건을 송부받은 항고법원은 이를 단독판사등의 인가처분에 대한 항고 또는 즉시항고로 보아 재판절차를 진행하게 된다(사보규 제4조 제9항).

라. 배당표에 대한 이의신청(사보규 제5조)

1) 이의신청 대상

사법보좌관규칙 제2조 제1항의 규정에 따라 사법보좌관이 한 처분 가운데 사법보좌관이 작성한 배당표에 대하여는 이의신청을 할 수 있다(사보규 제5조 제1항). 당사자는 동일 사건의 배당절차에서 두 번에 걸쳐 이의를 할 수 있다. 즉 사법보좌관의 처분(배당표)에 대하여 규칙에 기한 ‘이의신청’을 할 수 있고, 그 이의신청을 심사한 같은 심급 판사의 처분(배당표)에 대하여 다시 민사집행법 제151조 소정의 ‘이의’를

할 수 있다.

2) 이의신청 방식

사법보좌관의 작성한 배당표에 대하여 하는 이의신청은 대상이 된 처분의 표시와 그 처분에 대한 이의신청 취지를 밝히는 방법으로 사법보좌관에게 하여야 한다(사보규 제5조 제2항).

채권자는 배당기일에 출석하여서만 이의를 할 수 있고, 채무자는 배당기일에 출석하여 이의를 하거나 법원에 배당표원안이 비치된 이후 배당기일이 끝날 때까지 사이에는 서면으로 이의를 할 수 있다(민집 제151조). 한편, 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 이의신청은 민사집행법 제151조의 규정에 따른 기간 내에 하여야 하므로(사보규 제5조 제3항), 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 이의신청을 함에 있어도, 채권자는 배당기일에 출석하여 말로써 이의신청을 하여야 하고, 채무자는 배당기일에는 말로써 이의 신청을 하는 것으로 족하되, 배당표원안이 비치된 이후 배당기일이 끝날 때까지 사이에는 서면으로 이의신청할 수 있다 할 것이다.

3) 사법보좌관의 사건처리

사법보좌관은 이의신청을 받은 경우, 민사집행법 제152조 제1항, 제2항의 규정에 따라 이의에 관계된 채권자로 하여금 이의신청에 대하여 진술(답변)을 하게하고, 관계인의 이의신청을 정당하다고 인정하거나 다른 방법으로 합의한 때에는 이에 따라 배당표를 경정하여 배당을 실시하여야 한다(사보규 제5조 제4항 제1호). 사법보좌관이 이러한 절차를 진행하지 못할 경우에는 배당기일을 중지한 후 이의신청 사건을 지체 없이 판사에게 송부하여야 한다(사보규 제5조 제4항 제2호).

한편, 민사집행법 제148조에 규정되지 않은 채권자가 이의신청을 한 경우 에도 그러한 이의가 부적법하여 각하한다는 취지의 판단은 사법보좌관규칙 제4조 제6항 제2호 및 제6호와의 균형상 판사가 하는 것이 타당하다. 따라서 사법보좌관은 배당기일을 중지한 후 사건을 판사에게 송부하여야 한다.

4) 판사의 사건처리

이의신청 사건을 송부받은 판사는 배당표를 작성하여 당해 기일 또는 속행된 기일에 배당기일을 실시하여야 한다(사보규 제5조 제5항). 이에 따른 판사의 처분에 대하여는 해당 법률에 의하여 한 처분으로 보고 해당 법률에서 정하고 있는 절차에 따라 불복할 수 있다(사보규 제5조 제6항). 따라서 민사집행법의 규정에 따른 이의 및 배당이의 소 제기 등의 불복절차가 동일하게 적용된다.

[2 - 1] 사법보좌관처분에 대한 이의신청서

이의신청서

사법보좌관의 결정에 대하여 법원조직법 제54조 제3항에 따라 이의를 신청합니다.

사건번호 :

사 건 명 :

신청인	성명	
	주소	
	연락처	
이의신청 대상처분	처분일자	
	처분내용	
신청취지		
신청이유		

접 수 인

20 . . .

신청인 (서명 또는 날인)

[2 - 2] 사법보좌관처분에 대한 인가결정

○○지방법원

결 정

사 건 20 타경○○○○ 부동산임의경매

채권자 김갑동

채무자 이을병

소유자 박정무

주 문

이 사건 사법보좌관의 처분(매각허가결정)을 인가한다.

이 유

채무자의 이의신청은 이유 없다고 인정되므로, 사법보좌관규칙 제4조 제6항 제5호를 적용하여 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사 ○ ○ ○ 인

[2 - 3] 이의신청서 각하결정

서울중앙지방법원

결 정

사 건 20 타경○○○ 부동산임의경매

채권자 ○○○

○○시 ○○구 ○○로 ○○○

채무자 ○○○

(이의신청인) ○○시 ○○구 ○○로 ○○○

송달장소 ○○시 ○○구 ○○로 ○○○

소유자 채무자와 같음

주 문

이의신청인 ○○○의 이의신청서(즉시항고장)를 각하한다.

이 유

이의신청인 ○○○는 이 법원(사법보좌관)의 20 . . .자 매각허가결정에 불복하여 20 . . . 이의신청서를 제출하였으나, 거기에 민사집행법 제130조 제3항 소정의 보증제공서류가 붙어 있지 아니하고, 이 법원이 상당한 기간을 정하여 보정을 명하였음에도 불구하고 이의신청인이 이를 보정하지 아니하였으므로, 사법보좌관규칙 제4조 제6항 제6호를 적용하여 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사 ○ ○ ○ (인)

[2 - 4] 사법보좌관의 취소결정에 대한 경정결정

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타정 ○○○ 부동산강제(임의)경매

채 권 자 ○○○

(이의신청인) ○○시 ○○로 ○○○

채 무 자 ○○○

점소유자 ○○시 ○○로 ○○○

주 문

이 법원의 20 . . . 자 경매개시결정의 취소결정 및 이 사건 경매신청 기각결정을 모두 취소한다.

이 유

이 법원(사법보좌관)은 남을 가망이 없다는 이유로 주문기재와 같이 20 . . . 자로 경매개시결정을 취소하고, 이 사건 경매신청을 기각하는 결정을 하였다.

그러나 기록에 나타난 자료에 의하면, 신청채권자에 우선하는 선순위 채권으로 근저당권자 ○○○의 피담보채권액 ○○○○원, △△구의 당해세 ○○○원 등 합계 ○○○○원인 사실이 인정된다. 위 금원에 집행비용을 더하여도 최저매각가격인 ○○○○원에 미치지 못하므로, 남을 가망이 있다고 할 것이다.

그렇다면 이 법원의 20 . . . 자 경매개시결정의 취소결정 및 이 사건 경매신청기각결정의 취소를 구하는 채권자의 이의신청은 이유 있으므로, 사법보좌규칙 제4조 제6항 제3호에 따라 사법보좌관의 처분을 경정하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사 ○ ○ ○ ㉠